

الجامعة الإسلامية العالمية شيهاغونغ
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية



أصول الفقه

FSC-2311

إعداد

محمد فرقان الحكيم

محمد محفوظ الرحمن

قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

الاسبوع Week	الموضوع Topic	استراتيجيات التعليم والتعلم Teaching-Learning Strategy	استراتيجيات التقييم Assessment Strategy	نتيجة المادة التي توافقه Corresponding CLOs
1	- التمهيد: تعريف أصول الفقه، موضوعه، وأهميته. - الأدلة الشرعية: المتفق عليها والمختلف فيها.	المحاضرة ، والمناقشة	التقييم المستمر	١
2	القرآن: تعريفه، وخصائصه وحججه ودلالته على الأحكام.	إلقاء المحاضرة و المناقشة	التقييم المستمر	٢
3	السنة: تعريفها وأنواعها وحججها، وأقوال العلماء في خبر الآحاد.	إلقاء المحاضرة و المناقشة	التقييم المستمر	٣
4	- أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحججها. - الإجماع: تعريفه وشروطه.	المحاضرة والمناقشة والتطبيقات	التقييم المستمر	٣
5	- أنواع الإجماع وحججه. - القياس: تعريفه، وأركانه وحججه.	المناقشة، الأسئلة والأجوبة،	التقييم المستمر	٥
6	شروط القياس وأقسامه.	المحاضرة ، المناقشة،	التقييم المستمر	٥
7	- الاستحسان: تعريفه وأنواعه وحججه.	المحاضرة ، المناقشة،	التقييم المستمر	٥-٤
8	- المصلحة المرسل: تعريفها وحججها وشروط العمل بها. - العرف: تعريفه وأنواعه وحججه.	إلقاء المحاضرة والتدريبات	التقييم المستمر	٥-٣

9	- شرع من قبلنا: تعريفه وأقسامه وحججه. - قول الصحابي: آراء العلماء في حججه.	إلقاء المحاضرة المناقشة، والتدريبات	التقييم المستمر	٤-٥
10	- سد الذرائع: تعريفه وأنواعه وآراء العلماء في حججه. - الاستصحاب: تعريفه وأنواعه وحججه.	إلقاء المحاضرة المناقشة	التقييم المستمر	٤-٣
11	- تعريف الحكم وأقسامه. أنواع الحكم التكليفي: - الواجب: تعريفه وصيغه وأقسامه. - المندوب: تعريفه وأنواعه.	إلقاء المحاضرة والتطبيقات	التقييم المستمر	٥
12	- الحرام: تعريفه وصيغه وأنواعه. - المكروه: تعريفه وصيغه وأنواعه. - المباح: تعريفه وحكمه.	إلقاء المحاضرة والتطبيقات	التقييم المستمر	٤
13	- أنواع الحكم الوضعي: - السبب: تعريفه وأنواعه وحكمه. - الشرط: تعريفه وأنواعه. - المانع: تعريفه وأنواعه.	المحاضرة ، المناقشة،	التقييم المستمر	٥ ٤
14	- الصحيح والباطل. - العزيمة والرخصة وأنواع الرخصة.	المحاضرة ، المناقشة،	التقييم المستمر	٤
١٥	- شروط المحكوم فيه: أقسام المحكوم فيه: حق الله وحق العباد. - شروط المحكوم عليه: عوارض الأهلية.	المحاضرة ، المناقشة،	التقييم المستمر	٥

مبادئ علم أصول الفقه^(١)

تعريف أصول الفقه:

يُعرّف أصول الفقه باعتبارين: باعتباره مركّباً، وباعتباره علماً ولقباً على علم معيّن.

١- أصول الفقه باعتباره مركّباً:

أصول الفقه مركّب من كلمتين هما (أصول) و(الفقه).
(أ) الأصول لغة: جمع أصل، وهو: ما بُنى عليه غيره، ومنه أصل الشجرة الذي تنبني عليه الفروع.

واصطلاحاً: له عدة معانٍ أهمها ثلاثة هي:

- الدليل: كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة»، أي: دليلها.
- القاعدة: كقولهم: «الأمور بمقاصدها» أصل من أصول الشريعة، أي: قاعدة من قواعدها.

- الرّاجح: كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع.
- (ب) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له، يقال: فقه زيدُ المسألة أي: فهمها^(٢).
- واصطلاحاً: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية»^(٣).

(١) المبادئ العشرة لتعلّم العلوم نظمها العلامة محمد بن علي الصبّان الشافعي (ت ١٢٠٦هـ) بقوله:

إنّ مبادئ كل فنّ عشرة
الحدّ والموضوع ثمّ الثمرة
وفضله ونسبة والواضع
مسائل والبعض ببعض اكتفى
والاسم الاستمداد حكم الشارع
ومن درى الجميع حاز الشرفاً

(٢) القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص: (١٦١٤)، المصباح المنير للفيومي، ص: (٣٩٠).

(٣) نهاية السؤل للإسنوي (١/١٩)، جمع الجوامع للسبكي (١/٤٣). وعرفه الإمام الجويني في الورقات بأنه: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد».



٢- أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن:

هو: «معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»^(١).
أو: «معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة»^(٢).
فيتعرف الطالب على أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها.
كما يتعرف على قواعد استخراج الأحكام الشرعية من هذه الأدلة، وذلك بمعرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك.
والأحكام الشرعية هي: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح.
والمستفيد للأحكام هو المجتهد، القادر على الاستنباط، ويقابله المقلد.
وليس المجتهد وحده هو من يستفيد من أصول الفقه، بل يمكن أن يستفيد منه القضاة والمحامون ودارسو القانون، بل أيضاً دارسو التفسير والحديث واللغة والعلوم الاجتماعية وغيرهم.

الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه:

علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية وأفعال المكلفين، أما علم أصول الفقه فيبحث في الأدلة الإجمالية، وطرق استنباط الأحكام الشرعية منها.

❖ موضوعه:

الأدلة الشرعية الإجمالية الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها، مع معرفة حال المستدل.
فالأصولي يبحث مثلاً في القياس وحجيته، والعام وما يفيد، والأمر وما يدل عليه وهكذا.

(١) وهذا تعريف القاضي البيضاوي الشافعي، انظر: المنهاج للبيضاوي وشرحه للإسنوي (٦/١).
(٢) شرح الكوكب المنير للفتوح (٤٤/١)، علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيع، ص: (٥٨)،
أصول الفقه للخضري، ص: (١٣).

❖ أهميته وفائدته:

علم أصول الفقه من أشرف العلوم؛ لأنه الطريق الموصل إلى معرفة أحكام الله تعالى.

قال الإمام الرازي: «أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه»^(١).
وقال الإمام القرافي: «لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير»^(٢).
وقال ابن خلدون: «وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة»^(٣).
وقال ابن بدران: «واعلم أنه لا يمكنُ للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعواماً، ومن ادّعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة»^(٤).

❖ ومن فوائد دراسته:

١. معرفة ما يصح الاستدلال به وما لا يصح، فليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به.
٢. معرفة مراتب الأدلة وما يقدّم منها، وطرق الجمع أو الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض.
٣. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس وقواعد سليمة.
٤. معرفة أسباب اختلاف الفقهاء بمعرفة أصولهم التي بنوا عليها أحكامهم، والقدرة على الموازنة والترجيح بين أقوالهم.
٥. معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجدّ من حوادث على مرّ العصور^(٥).

(١) المحصول للرازي (٢/ ٤٩٩).

(٢) نفائس الأصول في شرح المحصول لابن العربي (١/ ١٠٠).

(٣) مقدمة ابن خلدون، ص: (٤٥٢).

(٤) المدخل لابن بدران، ص: (٤٨٩).

(٥) علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة، ص: (٨٥).

الأدلة

تعريف الدليل:

لغة: المرشد الذي يدلّ على الطريق، والعلامات التي يستدلّ بها.
واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

أنواع الأدلة:

١. أدلة أصلية متفق عليها: وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
٢. أدلة تبعية مختلف فيها: وهي قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، والمصلحة المرسلّة، وسدّ الذرائع، والاستحسان، والعرف.

الدليل الأول: القرآن الكريم

تعريف القرآن:

لغة: مصدر للفعل قرأ.
واصطلاحاً: كلامُ الله تعالى المنزّل على محمد ﷺ، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبّد بتلاوته، المعجّز بأقصر سورة منه.

• المنزّل على محمد ﷺ: كما قال تعالى: ﴿وإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٢) نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿الشعراء: ١٩٢-١٩٤﴾، وخرج بهذا القيد ما
نزل على غيره من الأنبياء، كصالح إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى،
وإنجيل عيسى عليهم السلام.

• المنقول إلينا بالتواتر: فالقرآن جميعه قطعي الثبوت، وقد تكفل الله
بحفظه من التبديل والتحريف قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
[الحجر: ٩]، وخرج بذلك ما نقل إلينا عن الأحاد كالقراءات الشاذة.

- **الْمُتَعَبَّدُ بِتَلَاوَتِهِ:** فكل حرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وخرج بذلك منسوخ التلاوة كآية الرجم، والحديث القدسي.
- **الْمُعْجِزُ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ:** فالقرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، فلا قدرة لأحد أن يأتي بمثله، ولا بسورة منه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، وخرج بذلك الأحاديث القدسية، فإنها غير معجزة^(١).

✽ أحكام القرآن:

تشمل أحكام القرآن:

- ✽ **الأحكام الاعتقادية:** كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.
- ✽ **الأحكام الخلقية:** كالتحلي بالأخلاق الفاضلة، والبعد عن الرذائل.
- ✽ **الأحكام العملية:** كالعبادات، والمعاملات، وأحكام الأسرة، والعقوبات وغيرها.

✽ بيان القرآن للأحكام:

بين القرآن الكريم الأحكام كلها، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

قال الإمام الشافعي: «فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»^(٢).

وهذا البيان على نوعين:

١. البيان بقاعدة شرعية عامة تدرج تحتها الجزئيات، كالأمر بالعدل

(١) الفرق بين القرآن والحديث القدسي: أن القرآن قطعي الثبوت فهو متواتر كله، بخلاف الحديث القدسي، فمنه الصحيح والضعيف والموضوع، والقرآن معجز ومُتَعَبَّدُ بِتَلَاوَتِهِ، بخلاف الحديث القدسي.

(٢) الرسالة للشافعي، ص: (٢٠).

والإحسان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]، والأمر بالوفاء بالالتزامات والعقود في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

٢. البيان المفصل بذكر الجزئيات وتفريعات الأحكام، كآيات المواريث والعقوبات والحدود.

❦ دلالة القرآن على الأحكام:

القرآن منقول بالتواتر، فشبوته قطعي لا شك فيه، أما دلالته على الأحكام فهي إما:

١. دلالة قطعية: لا تحتمل إلا معنى واحداً، وهذا النوع قليل في القرآن، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، فهو نص قطعي الدلالة على أن حد الزنا مئة جلدة، لا زيادة فيها ولا نقصان.
٢. دلالة ظنية: تحتمل أكثر من معنى، ولم يحدد الشارع المعنى المراد منه، بل ترك ذلك لاجتهاد المجتهدين، وأكثر دلالات نصوص القرآن على الأحكام من هذا النوع.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، فلفظ (لامستم) يحتمل معنيين: الجماع، وملامسة البشرة^(١).

❦ حجية القراءة الشاذة:

تنقسم قراءات القرآن إلى:

١. قراءة متواترة: وهي: ما صحّ سندها، ووافقت اللغة ولو بوجه، ووافقت رسم

(١) حملة الحنفية على الجماع، فذهبوا إلى أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وحمله الشافعية على لمس البشرة، فذهبوا إلى نقض الوضوء بلمس بشرة المرأة، وقيد المالكية والحنابلة بالشهوة. انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (١/ ١١٣).

المصحف العثماني^(١).

٢. قراءة شاذة: وهي: ما نُقل إلينا نقلا غير متواتر، وهي ما عدا القراءات السبع، وقيل: ما وراء العشر^(٢).

ومن أمثلتها:

• قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في آية الكفارة: ﴿فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾^(٣).

• قراءة ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا﴾^(٤).

• قراءة عائشة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(٥).

• قراءة سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّ﴾^(٦).

وقد اختلف الأصوليون في حجيتها على قولين:

الأول: أنها ليست بحجة، وقال به كثير من الأصوليين، وهو المشهور عن مذهب الشافعي^(٧).

الثاني: أنها حجة؛ لأنها دائرة بين كونها قرآنا، وبين كونها خبرا؛ لأن راويها يخبر أنه سمعها من النبي ﷺ، وكلاهما يُحتج به، وهذا مذهب الحنفية

(١) انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (١/٥٣-٥٤).

(٢) البرهان للجويني (١/٤٢٧)، غاية الوصول شرح لب الأصول لذكرى الأنصاري، ص: (٣٢).

(٣) روى قراءتهما ابن جرير الطبري في التفسير وغيره، وهي ثابتة.

(٤) فتح الباري لابن حجر (١٢/٩٩). وقد انعقد الإجماع على أن أول ما يُبدأ بقطعه من السارق هو

يده اليمنى. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص: (١٣٥)، والمغني لابن قدامة (٨/٢٦١).

(٥) رواها الترمذي، وقال: حسن صحيح.

(٦) رواها الدارمي والبيهقي وغيرهما.

(٧) لأنها ليست بقرآن؛ لعدم التواتر، ولا احتمال أن تكون مذهباً للصحابي، وإليه ذهب الباقلاني

والجويني، والغزالي، وابن العربي، والآمدي، وابن الحاجب، والنووي.

والحنابلة وجمع من المالكية والشافعية^(١).

ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، فمن أوجبه كالحنفية والحنابلة استدّل بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا السابقة، ومن لم يوجبه كالشافعية والمالكية في الأظهر لم يستدلّ بهذه القراءة^(٢).

التدريب

◀ ضع عبارة (قطعي الدلالة) أو (ظني الدلالة) مقابل ما يناسبها من النصوص الآتية.

١. قال تعالى: ﴿لَلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]. (.....)
٢. قال تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. (.....)
٣. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. (.....)
٤. قال تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]. (.....)
٥. قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (.....)

◀ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة مما يلي:

١. أغلب دلالات القرآن على الأحكام الشرعية قطعية. ()
٢. نصوص القرآن جميعها متواترة، قطعية الثبوت. ()
٣. لا خلاف في حجّة القراءة الشاذّة. ()
٤. الأحاديث القدسية معجزة في لفظها. ()
٥. قطعي الثبوت هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. ()
٦. من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والإجماع ()

(١) كأبي حامد، والماوردي، والرويانى، وأبي الطيّب الطبري، والرّافعي. انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ص: (٣٢)، البحر المحيط للزركشي (١/ ٤٧٥).

(٢) أصول الفقه للسلمي، ص: (١٠١).

الدليل الثاني: السنة النبوية

تعريفها:

لغة: الطريقة المتبعة، محمودة كانت أو مذمومة.
 واصطلاحاً: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير^(١).
 مثال القول قوله ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)^(٢).
 ومثال الفعل حديث: (كَانَ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ)^(٣).
 ومثال التقرير: سكوته ﷺ عن أكل الضَّبِّ من قبل خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مما دَلَّ على إباحته^(٤).

ومن السنة قول الصحابي: «من السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنّا نفعل في عهده ﷺ»، كقول أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»^(٥)، وقول أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا»^(٦).

(١) التقرير: أن يفعل أحد الصحابة بحضرته ﷺ فعلاً، أو يقول قولاً فيمسك ﷺ عن الإنكار ويسكت، وهو حجة كالقول إذا كان واقفاً بين يديه؛ لأنه لا يجوز في حقه ﷺ تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ سكوته يدل على جواز ذلك، وكذا على الصحيح إذا وقع في زمانه ﷺ لا بحضرته إن علم به ولم ينكره، كعلمه ﷺ بأنّ معاذاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يصلي بقومه إماماً بعد أن يصلي معه ﷺ مأموماً، ومنه استدلال الشافعية على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.

(٢) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.

(٣) ويدخل في السنة كتاباته ﷺ ورسائله، مثل كتبه للملوك كقيصر، وإشارته، مثل: ردّه ﷺ السلام وهو في الصلاة بالإشارة، وتركه عن الفعل مع وجود المقتضي وعدم المانع، تركه الأذان والإقامة لصلاة العيد.

(٤) متفق عليه. ومن ذلك استدلال الشافعية على قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة بحديث قيس بن قهد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (رأى رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فسكت ﷺ) رواه الترمذي وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (٢/ ٢٨٧).

(٥) أخرجه أبو داود، قال ابن حجر: إسناده صحيح.

(٦) رواه البخاري.

حُجَّةُ السَّنة:

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي حجة يجب الرجوع إليها، والدليل على حجيتها:

١. أن الله تعالى أمر بطاعة النبي ﷺ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا ءَأَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

٢. السنة وحي من الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣]، والوحي وحيان، وحي متلو: وهو القرآن، ووحي غير متلو: وهو السنة.

٣. ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

٤. الأمر بالرد إلى الرسول ﷺ عند التنازع والاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

٥. قوله ﷺ: (فعلیکم بستتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسکوا بها وعصوا علیها بالنواجذ)^(١).

٦. قوله ﷺ: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، وإنّ ما حرّم رسول الله كما حرّم الله)^(٢).

٧. إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاحتجاج بالسنة في الأحكام الشرعية^(٣).

(١) أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه أبو داود ونحوه عند الترمذي في سننه، وقال: حسن صحيح.

(٣) انظر: الرسالة للشافعي، ص: (٨٤)، مقرر الفقه وأصوله، ص: (١٠٠-١٠١).

❁ أنواع السنة:

١. **المتواتر:** وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ويكون في الأصل عن مشاهدة، أو سماع، وهو حق مقطوع بصحته، ويفيد العلم الضروري اليقيني، مثل: بعثة النبي ﷺ، وعدد الصلوات، والمسح على الخفين. وهو نوعان:

• **لفظي:** وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الرواة، كقوله ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)^(١).

• **معنوي:** وهو ما اتفق رواه على معناه دون ألفاظه، كأحاديث الشفاعة، والحوض، والصراط، والميزان، ورفع اليدين في الدعاء^(٢).

٢. **الآحاد:** وهو ما لم يصل حدّ التواتر، كأن رواه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، مثل أكثر الأحاديث، وهو ظنيّ الثبوت يفيد الظن، وربما أفاد العلم بالقرائن. وينقسم باعتبار عدد طرقه إلى: مشهور وعزيز وغريب. كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى: صحيح وحسن وضعيف.

❁ العمل بأحاديث الآحاد:

يُعمل بحديث الآحاد بشرط صحته عن رسول الله ﷺ برواية ثقة في دينه، معروف بالصدق في حديثه، عاقل لما يحدث، ضابط لما يرويه، وبشرط أن لا يكون الخبر مخالفاً لحديث أهل العلم بالحديث^(٣).

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) قال الناظم:

ومَنْ بنى الله بيتاً واحتسب	مما تواتر حديث من كذب
ومسح خفين وهذي بعض	ورؤية شفاعته والحوض

(٣) المستصفى للغزالي (١/ ١٥٥)، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي، ص: (٢١٦). وأجاز

ومن الأدلة على العمل بخبر الواحد: (١)

١. ما تواتر عنه ﷺ من إنفاذه أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس.
٢. إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على قبول خبر الواحد عن رسول الله ﷺ، واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة، منها: تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد (٢).

✽ العمل بالحديث المرسل:

تنقسم أحاديث الآحاد إلى مسند متصل، ومُرسل، وهو عند المحدثين: ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ مما سمعه من غيره، وعند الأصوليين: ما سقط من سنده بعض رواته، مثاله: ما رُوي عن سعيد بن المسيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نهى عن المزينة والمحاكلة) (٣).

والحديث المسند حجةٌ بشروطه، أما المرسل فقد اختلف العلماء في

=

جمع من العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط: أن لا يكون شديد الضعف. وأن يكون مندرجاً تحت أصل عام. وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله.

(١) انظر: الرسالة للشافعي، ص: (٤١٠ - ٤١٩)، معالم أصول الفقه للجيزاني، ص: (١٤٢).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: «وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأبلغوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به، والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٧٧).

(٣) أخرجه مسلم. والمزينة: بيع الرطب على النخل بالتمر كيلاً، أو بيع العنب على الكرم بالزبيب كيلاً. والمحاكلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض.

حجّة^(١)، فاحتج به الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، وردّه جمهور المحدثين؛ للجهل بالساقط في الإسناد، ومذهب الإمام الشافعي عدم الاحتجاج به إلا بشروط منها:

١. أن يُسنده غير مرسله.
 ٢. أن يكون التابعي الذي أرسله من الكبار، ولا يرسل عمن فيه علة من جهالة ونحوها.
 ٣. أن يعتضد ويتقوى بقول صحابي، أو بقول أكثر العلماء^(٢).
- ومن الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل نقض الوضوء بلمس المرأة، وبالفقهية في الصلاة^(٣).

✽ أفعال النبي ﷺ:

- تنقسم أفعال النبي ﷺ إلى أربعة أقسام هي:
١. أفعال خاصة به ﷺ: كوصاله في الصوم، وجمعه أكثر من أربع نسوة، ويحرم الاقتداء به ﷺ في هذه الأفعال.

(١) قال عنه الحافظ العراقي في ألفيته:

وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ وَتَابَعُوهُمَا بِهِ وَذَانُوا
وَرَدَّهُ جَمَاهُ الرُّنَّادُ لِلجَّهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الإسْنَادِ
وَصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنْهُمْ نَقَلَهُ وَمُسْلِمٌ صَدَرَ الْكِتَابِ أَصْلَهُ

ويستثنى من ذلك مرسل الصحابي وهو: ما أخبر به الصحابي من قول النبي ﷺ أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، فهو حجة عند جمهور العلماء؛ لأنّ الصحابي لا يروي عادةً إلا عن صحابي مثله، والصحابة كلّهم عدول.

- (٢) ولذا قبل مراسيل سعيد بن المسيّب بلا شرط؛ لأنّه تتبّع مروياته فوجدها جميعها عن الصحابة، والغالب أنّ الساقط فيها صهره أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انظر: الرسالة للشافعي، ص: (٤٦١-٤٦٧).
- (٣) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للخن، ص: (٤٠٣) وما بعدها.

٢. أفعال جبليّة: وهي التي فعلها ﷺ بمقتضى العادة أو الطبيعة البشرية، كالقيام، والقعود، وطريقة الأكل، والشرب، فهذا القسم يفيد الإباحة؛ لأنه ﷺ لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، إلا إن دلّ دليل على فعلها بصفة معينة للاقتداء، كالأكل باليمين، والأكل مما يلي.

٣. أفعال بيانيّة: يقصد بها التشريع والتعبد، وتكون بيانا لمجمل، كأفعال الصلاة والحج مثلا فهذه للتأسي والاقتداء به، وتأخذ حكم ما بيّنته، فإن كان المبيّن واجبا كان الفعل المبيّن له واجبا، وإن كان مندوبا كان مندوبا.

٤. ما فعله ﷺ ابتداء، ولم يكن خاصا به، ولا جليّا، ولا بيانا لمجمل، والأصل فيه أنه للتشريع؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. فإن كان على وجه القربة والطاعة فقد اختلف في حكمه ف قيل: بالوجوب؛ لأنه الأحوط، وقيل: بالنّدب؛ لأنه أقل الطلب، وقيل بالتوقف؛ لعدم ظهور الترجيح. وإن لم يكن على وجه القربة والطاعة حمل على الإباحة؛ لأن الأصل عدم التعبد، وقيل: على النّدب.

ومن أمثلة هذا النوع الرابع: جلوسه ﷺ بين الخطبتين يوم الجمعة، وذهابه ﷺ يوم العيد من طريق ورجوعه من آخر، وسواكه ﷺ عند دخول البيت، وترجله ﷺ وتكحله.

✽ أحوال السنة مع القرآن:

للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال هي:

١. السنة المؤكّدة: وهي المقرّرة لما جاء في القرآن، كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب وبالسنة.

٢. السنة المبيّنة: وهي المفصّلة لما أجمل في القرآن من الأحكام، كبيانه ﷺ صفة الصلاة والزكاة المجملة في القرآن.

٣. السنة المستقلّة: وهي المنشئة لحكم سكت عنه القرآن، كتحریم الجمع بين المرأة

وعمتها، أو خالتها؛ لقوله ﷺ: (لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)^(١)، وتحريم أكل السباع، وكلّ ذي مخلب من الطيور؛ لحديث: (نهى رسول الله ﷺ عن كلّ ذي ناب من السباع، وعن كلّ ذي مخلب من الطير)^(٢).

❖ دلالة السنة على الأحكام:

من نصوص السنة ما هو قطعي الثبوت كالمتواتر، ومنها ما هو ظني الثبوت كأحاديث الآحاد، أما من حيث الدلالة فكلّ من الحديث المتواتر والآحاد قد يكون قطعي الدلالة، أو ظني الدلالة.

مثال قطعي الدلالة: حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)^(٣)، فلفظ «الصاع» قطعي لا يحتمل إلا معنى واحداً. ومثال ظني الدلالة: قوله ﷺ: (لا صلاة للذي خلف الصف)^(٤)، لأنه يحتمل لا صلاة كاملة، أو صحيحة.

التدريب

◀ مثل لما يلي بمثال واحد:

١. سنة تقريرية.
٢. فعل خاص به ﷺ.
٣. حكم ثابت بحديث متواتر.
٤. سنة مؤكدة لحكم في القرآن.
٥. سنة مفصلة لحكم مجمل في القرآن.

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه مسلم.

(٤) أخرجه أحمد وحسنه وابن خزيمة وابن حبان. ولذا اختلف في صلاة المنفرد خلف الصف، فالجمهور على صحة صلاته مع الكراهة، وحملوا الحديث بأن معناه: لا صلاة كاملة، مثل حديث: (لا صلاة بخضرة الطعام، ولا هو يُدافعُه الأخبثان) رواه مسلم. وقال الحنابلة ببطلان صلاته، وفسروا الحديث بمعنى: لا صلاة صحيحة.

الحديث المرسل :

الحديث المرسل في اصطلاح الأصوليين : هو قول العدل الذي لم يلق النبي ﷺ : قال رسول الله ، سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلقاً ، أي كل ما لم يتصل إسناده .

ولا خلاف في قبول مرسل الصحابي : لأن الصحابة كلهم عدول . وأما مرسل غير الصحابي : فهو مقبول أيضاً عند الجمهور غير الشافعي ؛ لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل الحديث ولا يستجيز الرواية إلا وهو جازم بأن النبي ﷺ قال ذلك^(١) .

ولا يقبل الحديث المرسل عند الشافعي إلا إن تأيد بأحد أمور خمسة :

١ - أن يكون من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب والزهري والحسن البصري والشعبي وابن سيرين ونحوهم .

٢ - أن يؤيده حديث مسند في معناه .

٣ - أن يوافقه مرسل مقبول عند العلماء .

٤ - أن يؤيده قول صحابي .

٥ - أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء .

ودليل الشافعي أن قبول خبر الراوي مشروط بمعرفة عدالته ، وعدالة الأصل في المرسل لم تعلم ؛ إذ لا يعرف اسمه ولا وصفه ، فإن لم نعلمه تعين رده . وإذا انضم إليه أحد المؤيدات الخمسة السابقة ، ترجح صدقه على كذبه ، وساغ العمل به^(٢) .

أفعال النبي ﷺ :

(٣) أفعال النبي ﷺ ثلاثة أنواع :

(١) إرشاد الفحول : ص ٥٧ .

(٢) الإيهام للسبكي : ٢٢٥/٢ .

(٣) الإحكام للآمدي : ١/٨٩ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : ٢/٢٢ ، التقرير والتحجير : ٢/٣٠٢ .

أولاً - الأفعال الجبليّة^(١) التي تصدر عن الرسول ﷺ بحكم الطبيعة الإنسانية : كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم والمشي ، هي على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته ، ولا يجب علينا التأسّي والاعتداء به فيها ، فإن قام الدليل على ندها أو سنيّتها كالأكل باليمين ، كانت تشريعاً .

ومنها ما صدر عنه ﷺ بمقتضى الخبرة والتجربة في الشؤون الدنيوية من تجارة وزراعة وتديير حربي ووصف دواء لمريض ، لاتعدّ تشريعاً ؛ لأنها باجتهاد وخبرة شخصية ، لا بالوحي الإلهي ، ولهذا لما رأى في غزوة بدر النزول بالجند في مكان معين ، قال له الحُباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ، فقال الحُباب : ليس هذا بمنزل ، وأشار لمنزل آخر قرب الماء ، فنزل الجيش فيه . ولما رأى النبي ﷺ أهل المدينة يؤبرون النخل^(٢) ، أشار عليهم بالألا يؤبروا ، فتركوا التأبير ، وتلف التمر ذلك العام ، فقال لهم الرسول ﷺ : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » .

ثانياً - الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي ﷺ : كإباحة الوصال في الصيام ، واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل ، وإباحة التزوج بأكثر من أربع نسوة ، واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده ، وغير ذلك ، وحكم هذه الخصائص أنه لا يقتدى به فيها ، وتعد خاصة به .

ثالثاً - الأفعال المجردة عما سبق ، والتي قصد بها التشريع : فهذه نطالب بالتأسّي والاعتداء بها ، وتعرف صفتها وجوباً أو ندباً أو إباحة مما يأتي :

أ - فإن كانت هذه الأفعال واردة بياناً لمحمل في القرآن أو تقييداً لمطلق أو تخصيصاً لعام ، فحكمها حكم ما بيّنته من وجوب وندب ، ويعرف البيان إما بصريح

(١) الجبلة الإنسانية : هي الحلقة .

(٢) تأبير النخيل : تلقيحه بطلع الذكور ووضعه على طلع الإناث .

القول ، مثل قوله في الصلاة : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » ، وفي الحج : « خذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » ، وإما بقرائن الأحوال ، كفعل صالح للبيان عند الحاجة إليه ، كقطعه يد السارق من الرسغ ، فإنه بيان لقوله تعالى : ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٢٨/٥] ، وكتيمه إلى المرفقين ، فإنه بيان لقوله تعالى : ﴿ فَاْمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ﴾ [النساء : ٤٣/٤] ، فالبيان يكون تابعاً للمبين في الوجوب والندب والإباحة .

ب - وإن وردت هذه الأفعال ابتداء دون بيان الشيء : فإما أن تعرف صفتها الشرعية أو لا تعرف ، فإن عرفت صفتها من وجوب أو ندب أو إباحة ، فإن أمته في الفعل مثله ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧/٥٩] ، وقوله سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب : ٢١/٣٣] ، ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله ﷺ احتجاجاً واقتداء به في وقائع كثيرة ، كما فعل عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود ، وقوله : « لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك » .

فإن جهلت صفة الفعل الشرعية : فإن ظهرت فيه صفة القربة ، بأن كان مما يتقرب به إلى الله عز وجل ، كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها ، دلّ الفعل على الندب .

وإن لم يظهر فيه صفة القربة ، كالبيع والمزارة ، كان مفيداً للإباحة ، وهو الراجح عند العلماء ؛ لأن الإباحة هي القدر المتيقن ، فلا يثبت الزائد عليها إلا بدليل ، ولا دليل . وفي اتجاه آخر : يكون الفعل دالاً على الندب ؛ لأن الفعل لا بد من أن يكون لقربة ، وأقل ما يتقرب به المندوب .

والخلاصة : أن الأفعال الإنسانية المحضة والخبرات والتدابير الدنيوية والخصوصيات ، لا تعد تشريعاً ولا سنة مطلوبة ، وأما ما قصد به التشريع العام بصفة كونه صادراً عن النبي ﷺ بوصف الرسالة وأنه رسول ، فهو تشريع على الأمة اتباعه فيه .

الدليل الثالث: الإجماع

تعريفه:

لغة: العزم، ومنه قوله ﷺ: (من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)^(١)، والاتفاق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف: ١٥].
واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

فخرج بـ (اتفاق) وجود خلاف ولو كان المخالف واحداً^(٢).
وبـ (المجتهدين) خرج إجماع المقلّدين والعوام، وكذا إجماع غير الفقهاء كالنحويين وغيرهم.
وبـ (أمة محمد ﷺ) خرج اتفاق علماء الشرائع السابقة.
وبـ (بعد وفاته) خرج الإجماع في عصره ﷺ؛ لأنّ الدليل حصل بسنته ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

وبـ (حكم شرعي) خرج اتفاقهم على الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها.
ولا يشترط في الإجماع اتفاق مجتهد في كل الأعصار؛ لتعذر ذلك، كما لا يشترط على الصحيح انقراض عصر المجتهدين؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى تعذر الإجماع^(٣).

(١) أخرجه أبوداود وغيره، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره.

(٢) فليس من الإجماع على الصحيح اتفاق الأكثرية، ولا إجماع الخلفاء الراشدين، ولا إجماع العترة (أهل البيت)، ولا إجماع أهل المدينة عند غير المالكية الذين احتجوا به وقدموه على خبر الواحد إذا عارضه.

(٣) وذهب البعض إلى اشتراط انقراض عصر المجتهدين، وعلى هذا القول يجوز لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه، ولا يعتبر مخالفاً للإجماع؛ لأنه لم ينعقد، ولا بد كذلك من

ولا يشترط كذلك أن يمضي على اتفاقهم زمن، بل متى ما اتفقت كلمتهم، واستقرت آراؤهم، وعُلم ذلك منهم حصل بذلك الإجماع وانعقد.

❖ أمثلة على الإجماع:

١. إجماع أهل العلم قاطبة على حرمة الصلاة بالحدث.
٢. إجماعهم على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيّرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس.
٣. إجماعهم على أن الوطء يفسد الصوم.
٤. الإجماع على حجب ابن الابن بالابن، وتقديم الدين على الوصية.
٥. الإجماع على أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة.

❖ حجية الإجماع:

الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها، وهو حجة شرعية يجب العمل بها، ويحرم خرقه، ومن الأدلة على حجّيته:

١. قوله ﷺ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
وجه الاستدلال بالآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدلّ على أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً^(١).
٢. قوله ﷺ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)^(٢).

=
موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد وإلا لما تم الإجماع، بخلاف القول بعدم اشتراط انقراض عصر المجتهدين في ذلك. انظر: إحكام الأحكام للآمدي (٢٧/١).

- (١) انظر: معالم أصول الفقه للجزائري، ص: (١٦٠).
- (٢) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وله شواهد في الصحيحين، وقد روى عن جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عدّه بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي، انظر: المعتمد للزركشي، ص: (٥٧)، تخريج أحاديث المنهاج للعراقي، ص: (٢٢)، معالم أصول الفقه للجزائري، ص: (١٦٢).

ووجه الدلالة: أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه، فيكون ما أجمعوا عليه حقاً يجب اتباعه.

٣. النصوص من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة كقوله ﷺ: (فمن أراد بحبوة الجنة فيلزم الجماعة) ^(١).

❖ شروط الاستدلال بالإجماع:

١. أن يثبت بطريق صحيح: بأن يكون مشهوراً بين العلماء، أو ينقله ثقة واسع الاطلاع.
٢. أن لا يسبقه خلاف مستقر: فإن سبقه خلاف ممن يعتبر خلافه ولم يتراجع المخالف عن قوله فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها.

❖ أنواع الإجماع:

ينقسم الإجماع إلى:

١. إجماع قولي (صريح): وهو: أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم، بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام، ومثله: أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع ^(٢).
٢. إجماع سكوتي (إقرارى) وهو: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقي عن إنكاره، من دون خوف وإكراه ^(٣).

(١) رواه الحاكم في المستدرک (١ / ١١٤) وصححه. قال الإمام الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: «...ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها». الرسالة، ص: (٤٧٥ - ٤٧٦).

(٢) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب (١١ / ١٧٠). غاية الوصول شرح لب الأصول لتركيب الأنصاري، ص: (١١٣)، ومن الإجماع الفعلی: ما جرى عليه العمل بين المسلمين، أو ما كان يقضي به القضاة، ولم ينقل عن أحد إنكاره، كأنواع البيوع، وصيغ الأذان، وعدم الأذان لصلاحي العيدين والاستسقاء.

(٣) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب (١ / ١٧٠). فلا بد أن يبلغ جميع المجتهدين المعاصرين،

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم رجح بأن «السكوت علامة الرضا» فاعتبره حجة، وبعضهم رجح جانب المخالفة؛ لأنه «لا ينسب إلى ساكت قول» فلم يعتبره حجة^(١).

ومن أمثلة الإجماع السكوتي:

١. إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب التغريب عاما مع الجلد للزاني البكر، ولم يُعلم لهم مخالف فكان إجماعا سكوتيا.
٢. سقوط القطع عن السارق أيام المجاعة^(٢).
٣. سفر المرأة مع النساء الثقات حيث أمن الطريق^(٣).
٤. الإجماع على قتال مانعي الزكاة، فقد ثبت باجتهاد أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولم يخالفه في ذلك أحد.

وينقسم الإجماع كذلك إلى:

١. إجماع قطعي: وهو ما وجدت فيه جميع الشروط، ونُقل تواترا، مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنا.

ويتنشر فيهم، وأن تظهر علامة الرضا على الساكتين، وأن يمضي على سماعهم الفتوى أو الحكم زمن يتمكنون فيه عادة من النظر.

(١) ذهب جمهور الشافعية إلى أنه ليس بإجماع ولا حجة، وذهب آخرون إلى أنه إجماع وحجة، وآخرون إلى أنه حجة وليس بإجماع، انظر: البرهان للجويني (١ / ٢٧١)، قواطع الأدلة للسمعاني (٤ / ٢).

(٢) ثبت ذلك عن عمر وابنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وقد روي عن مروان بن الحكم أنه أتى بسارق في عام مجاعة فلم يقطعه، وقال: أراه مضطرا، فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة وعلماء العصر. الحاوي للماوردي (٣١٣ / ١٧).

(٣) وهو اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ﷺ. موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (٩٧٨ / ٢).

٢. إجماع ظني: وهو خلاف القطعي، كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

❖ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ:

لا بد للإجماع من دليل يستند إليه المجمعون، وهذا الدليل قد يكون من القرآن أو السنة أو القياس، أو المصلحة وقواعد الشريعة العامة. وفائدة الإجماع مع وجود الدليل: نقل الحكم من الظنية إلى القطعية، وتحريم المخالفة، وسقوط البحث عن حالة السند، أو عن دليل آخر.

❖ فَمَنْ الْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ عَلَى الْقُرْآنِ:

الإجماع على حرمة نكاح الجدّات وإن علون؛ لأنهن يدخلن تحت مسمى الأمهات في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

❖ وَمَنْ الْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ عَلَى السُّنَّةِ:

الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث عند فقد الأم؛ لأنّ الرسول ﷺ أعطى الجدة السدس، ولا يزيد نصيبها عن ذلك بخلاف الأم.

❖ وَمَنْ الْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ عَلَى الْقِيَاسِ:

١. إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قياساً على إمامته في الصلاة، حتى قالوا: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر ديننا.
٢. إجماعهم على إراقة الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة؛ قياساً على السمن.
٣. إجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير؛ قياساً على لحمه؛ لاشتراكهما في النجاسة والقذارة.

❖ وَمَنْ الْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ عَلَى الْاجْتِهَادِ وَالْمَصْلَحَةِ:

١. إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم، وكتابته على مصحف واحد.

٢. إجماعهم على النداء الأول لصلاة الجمعة الذي زاده عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لإعلام الناس بالصلاة لاسيما البعيدين منهم عن المسجد.

❦ أشهر كتب الإجماع:

١. «الإجماع» لأبي بكر بن المنذر (ت ٣١٨هـ).
٢. «مرتب الإجماع» لابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ)، مع «نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية (ت ٧٢٨هـ).
٣. «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جيب.

التدريب

◀ عرف الإجماع.

◀ اذكر دليلين على حجية الإجماع.

◀ مثل لما يلي:

١. إجماع قطعي.
٢. إجماع سكوتي.
٣. إجماع مستنده القياس.
٤. إجماع مستنده السنة.

◀ صحح الخطأ في العبارات التالية:

١. الإجماع هو المصدر الثاني من مصادر التشريع المتفق عليها.
 ٢. يشترط في الإجماع عند الجمهور انقراض عصر المجتهدين.
 ٣. أجمع العلماء على حجية الإجماع السكوتي.
- ◀ بالرجوع إلى الكتب الفقهية اذكر ثلاث مسائل أجمع عليها العلماء.



الدليل الرابع: القياس

تعريفه:

لغة: التقدير والمساواة، يقال: قِسْتُ الأرضَ بالمتَر، أي: قَدَرْتُها به، وفلان لا يُقاسُ بفلان، أي: لا يساويه ولا يُقَارَنُ به.
واصطلاحاً: إلحاق فرع بأصل في حكمٍ لِعِلَّةٍ جامعةٍ بينهما.
ومعنى ذلك: أنه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ألحقت في الحكم بواقعة أخرى تماثلها في العلة ثبت حكمها بالنص أو الإجماع.

أركان القياس:

أركانه أربعة وهي:

١. الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها نص ولا إجماع ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم، ويُسمى المقيس.
٢. الأصل: وهو الواقعة التي ورد في حكمها النص أو الإجماع، ويُسمى المقيس عليه.
٣. الحكم: وهو ما يقتضيه الدليل من وجوب أو ندب أو صحّة أو غير ذلك.
٤. العلة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي ثبت بسببه حكم الأصل في الفرع.

مثاله: قياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فالأصل هنا التأفيف، والفرع الضرب، والعلة الإيذاء، والحكم التحريم.

حُجَّةُ القياس:

- القياس حجة شرعية يعمل بها، خلافاً للظاهرية، ومن الأدلة على حجّيته:
١. قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]. أي: فقيسوا أنفسكم بهم - بني

- التّضير - والاعتبار مساواة الشيء بالشيء، وهو متحقق في القياس حيث يسوّي المجتهد بين الأصل والفرع في الحكم عند توفر العلة الجامعة بينهما.
٢. ما ورد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: (يا رسول الله وُلِدَ لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمُرٌ، قال: هل فيها من أورك؟ قال: نعم، قال: فأنتى ذلك؟ قال: لعلّه نزعهُ عِرْقٌ، قال: فلعلّ ابنك هذا نزعهُ عِرْق) ^(١)، فقد أرشد الرسول ﷺ الرجل إلى القياس فدَلَّ ذلك على حجّيته.
٣. ما ورد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امرأةً من جهينة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إِنَّ أُمِّي نذرت أَنْ تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجَّ عنها؟ قال: (نعم حُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لو كان على أُمكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) ^(٢).
٤. كتاب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في القضاء حيث قال فيه: (الفهم الفهم فيما أُدليّ إليك ممّا ليس في قرآن ولا سنة، ثمّ قس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه) ^(٣).
٥. إجماع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر ^(٤)، ولم يزل التابعون أيضاً ومن بعدهم من علماء الأمة على إجازة القياس وإثبات الأحكام به ^(٥).

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) رواه البيهقي (١٥٠ / ١٠)، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (١٢٧ / ١): «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول».

(٤) من ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام.

(٥) انظر: معالم أصول الفقه للجزاني، ص: (١٩٠).

❦ شروط القياس:

للقياس شروطٌ منها: ^(١)

١. أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتاً بنص، أو إجماع أو بهما.
 ٢. أن يكون حكم الأصل معقول المعنى؛ لثُمُكِنِ تعدية الحكم إلى الفرع، أما ما لا يعقل معناه بأن كان تعبدية كعدد الركعات فلا يصح القياس عليه؛ لعدم معرفة العلة ^(٢).
 ٣. ألا يكون الحكم خاصاً: كقوله ﷺ: (مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةٌ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) ^(٣)، فلا يقاس أحد على خزيمة بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في جعل شهادته كشهادة رجلين.
 ٤. ألا يكون الحكم منسوخاً، فالحكم المنسوخ لا يُقاس عليه، فلا يقال: لا تدخر لحوم الهدايا فوق ثلاث؛ قياساً على لحوم الأضاحي؛ لأنّ النهي عن ادّخار الأضاحي منسوخ.
 ٥. أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة، وإلاّ كان قياساً مع الفارق، فلا يقال: تجري الربا في التفاح قياساً على البر؛ لأنّ العلة في البر وهي كونه قوتا مطعوماً غير موجودة في التفاح.
 ٦. أن لا يخالف القياس نصّاً أو إجماعاً، وإلاّ كان قياساً «فاسد الاعتبار»، ولذا قال العلماء: «لا قياس مع النص»، فلا يصح قياس تزويج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها؛ لمصادمته النص وهو قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي) ^(٤).
- كما لا يصح قياس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الصيام عليه

(١) تضاف إلي هذه الشروط شروط العلة الآتي ذكرها.

(٢) فلا يصح قياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء عند من يقول به.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٤٦)، وحسنه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (١٩/٢).

(٤) رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

بجامع المشقة؛ لأن هذا مخالف للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب أدائها على المسافر.

❖ أقسام القياس:

ينقسم القياس إلى أقسام عدة منها: (١)

١- قياس العلة:

وهو ما كانت العلة فيه موجبةً لثبوت الحكم في الفرع، بأن تكون في الفرع أقوى منها في الأصل.

مثاله: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفف المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فالعلة وهي الإيذاء أقوى في الفرع وهو الضرب من الأصل وهو التأفف.

٢- قياس الدلالة:

وهو ما كانت العلة فيه دالة دلالة محتملة على ثبوت الحكم في الفرع لا موجبة له؛ لاحتمال وجود فارق بين الأصل والفرع، وهذا القياس أضعف من الأول.

مثاله: قياس الجمهور مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة عند

(١) من أقسام القياس عند الشافعية:

قياس الأولي: وهو ما كان الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه مثل: قياس ضرب الوالدين على التأفف بجامع الإيذاء.

وقياس المساوي: وهو ما كان الفرع مساوياً للأصل في الحكم من غير ترجيح مثل: قياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع التلف في كل منهما.

وقياس الأدنى: وهو ما كان الفرع أضعف في العلة من الأصل مثل: إلحاق النبيذ بالخمير في تحريم الشرب وإيجاب الحد. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٢٤).

ومن أقسامه كذلك:

القياس الجلي: وهو ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله.

والقياس الخفي: وهو ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص.

وجود النصاب والحول؛ لأنّه مألّ نام، وخالف الحنفية فقالوا بأنّ الزكاة لا تجب في مال الصبي؛ لأنّه غير مكلف؛ قياساً على سائر العبادات.

٣- قياس الشبهة:

وهو أن يتردد فرع بين أصليين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبهاً به، وهذا النوع أضعف أنواع القياس.

مثاله: العبد إذا قُتل فهل تجب فيه الدية كالأحرار، أو القيمة كالأموال؟ فمن جهة أنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن جهة أنه يُباع ويوهب ويوقف ويورث يشبه الممتلكات، فالحقه الجمهور بالأموال؛ لأنه أكثر شبهاً بها فيضمن بالقيمة، وألحقه الحنفية بالأحرار.

❖ شروط العلة ومسالكها: (١)

العلة أهم أركان القياس، وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم. وتسمى بالمناط، والمؤثر، والسبب، والمقتضي، والجامع، وغير ذلك (٢).

❖ شروط العلة:

من شروط العلة:

١- أن تكون مطردة منعكسة:

أي: كلّما وجدت العلة وُجد الحكم، وكلّما عُدمت عُدِم الحكم، والقاعدة أنّ «الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً».

(١) انظر: الخلاصة في أصول الفقه لكاملة الكواري، ص: (٨٥)، العلة لمبارك بقنه، ص: (٦) وما بعدها.
(٢) هناك فرق بين السبب والعلة والحكمة، فالعلة: ما كان مناسباً للحكم مناسبة يدركها المكلف، كالإسكار سبب لتحريم الخمر، والسبب أعم من العلة فإنه يطلق أيضاً على ما لا يُدرك معناه كزوال الشمس سبب لوجوب الظّهر، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.
أما الحكمة فهي المقصد الشرعي الذي شرع الحكم لأجله، فالحقصاص حكم شرعي علته القتل عمداً وعدواناً، وحكمته حفظ النفوس. انظر: البيان المأمول في علم الأصول لعبد الرحمن عبد الخالق، ص: (١٥٢).

أما إذا كانت العلة منتقضة بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلا يصح التعليل بها.

مثال العلة المطردة المنعكسة: القتل العمد العدوان علة لإيجاب القصاص، فإذا وجد القتل والعمد والعدوان وجد حكم القصاص، وإذا لم يوجد لم يثبت القصاص.

ومثال العلة المنتقضة: تعليل القصاص بالقتل فقط دون العمد والعدوان، فإن هذه العلة منتقضة، فقد يحصل القتل ولا يوجب القصاص، كقتل الخطأ، وشبه العمد، وقتل الصائل المعتدي.

٢- أن تكون ظاهرة غير خفية؛

أي: يمكن التحقق من وجودها في كل من الأصل والفرع بعلامة ظاهرة، كالإسكار فإنه علة يمكن التحقق من وجودها في الخمر وفي كل مُسكرٍ.

٣- أن تكون منضبطة؛

أي: لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، مثل القتل المانع للقاتل من الإرث، فهو علة لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول، فتُقاس عليه الوصية، فلو قتل الموصي له الموصي مُنع من الوصية بالقياس. بخلاف تعليل قصر الصلاة في السفر بالمشقة؛ لأن المشقة وصف غير منضبط؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ولذا عدل عنها الشارع وعلل بوصف منضبط وهو السفر.

٤- أن تكون متعدية؛

أي: غير قاصرة على حكم الأصل، بل يمكن تعديتها إلى الفرع. فإيجاب الكفارة على المفطر علقته الجماع في نهار رمضان، فلا يصح إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب قياساً على الجماع؛ لأن الحديث علق الكفارة على الجماع فهي قاصرة عليه^(١).

(١) هذا عند الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية والمالكية.

٥- أن تكون مناسبة للحكم:

أي: أن يحقق ربط الحكم بتلك العلة ما قصده الشارعُ بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر.

كالقتل العمد العدوان علة لإيجاب القصاص؛ لأنَّ في القصاص حفظ حياة الناس، والسرقة علة لقطع يد السارق؛ لأنَّ في ذلك حفظ أموال الناس، بخلاف التعليل بكون القاتل أسوداً أو طويلاً أو رجلاً، وكون السارق غنياً والمسروق منه فقيراً فإنها غير مناسبة للتعليل.

٦- أن لا تعود على الأصل بالإبطال:

«كل تعليل يعود على الأصل بالإبطال فهو باطل»، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة في حديث: (في أربعين شاةً شاةً)^(١) بدفع حاجة الفقير، ولذا أجازوا إخراج القيمة بدلاً من الشاة؛ لأنها أولى بدفع حاجته، وهذا التعليل يؤدي إلى عدم وجوب الشاة.

❦ مسالك العلة:

وهي: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة الموجودة في الأصل. وطرق إثبات العلة هي: النص، والإجماع، والاستنباط.

❦ أولاً: طريق النص:

وهو أن يدل دليل من الكتاب أو السنة على العلة التي من أجلها وضع الحكم. ولدلالة النص على العلة أقسام هي:

١. النص الصريح: وهو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة. وله ألفاظ منها: من أجل، كي، ونحوها، كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَجَلْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].
٢. النص غير الصريح (الظاهر): وهو ما دل على العلة مع احتمال غيرها احتمالاً مرجوحاً.

(١) رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وله ألفاظ منها: اللام ، الباء، إن، فإن، الفاء، كقوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ أَنْ يَكُونُ لِلْعَاقِبَةِ﴾ [إبراهيم: ١] فاللام هنا للتعليل، وتحتمل أن تكون للعاقبة.

وقوله تعالى: ﴿فِظْلَمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] وقوله ﷺ في الهرة: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)^(١)، ويقاس عليها الفأر ونحوه مما يسكن في البيوت؛ لصعوبة التحرّز.

٣. الإيماء والتنبيه: وهو فهم التعليل من لازم النص ومقارنه لا من وضعه. كتعليل الحكم بالفاء في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. أو بصيغة الجزاء في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

أو وقوع الحكم جواباً لسؤال فيجعل ما في السؤال علة للحكم، كقول الأعرابي للنبي ﷺ: واقعتُ على امرأتي في رمضان، فقال ﷺ: (اعتق رقبة)^(٢) فإنه يدل على أن الوقاع علة للعتق.

❖ ثانياً: طريق الإجماع:

كأن يُجمع المجتهدون على أن هذا الحكم علته كذا ، كالإجماع على أن الصغر علة الولاية في المال، فتُقاس عليه الولاية في الزواج.

❖ ثالثاً: طريق الاستنباط:^(٣)

ومن طرق استنباط العلة:

(١) أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه النووي كما في المجموع (١/ ١٧١).

(٢) رواه البخاري ومسلم.

(٣) هناك ثلاثة مصطلحات متقاربة لها أهمية خاصة في استنباط العلة وهي:

١. تخريج المناط: ومعناه: استخراج العلة غير المنصوصة كالإسكار في الخمر.
٢. تنقيح المناط: ومعناه: حذف ما لا يصلح للعلة، كالأحمرار، والسائلية في الخمر.
٣. تحقيق المناط: ومعناه: التأكد من حصول العلة في واقعة أخرى؛ لتأخذ نفس الحكم؛ كالتأكد من وجود علة الإسكار في الكحول، والأفراص المخدرة.

الدَّلِيلُ السَّادِسُ: الاستِحْسَانُ

تعريفه:

لغةً: عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا.

واصطلاحًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٍّ أقوى من الأول. ومعناه: أن القياس يقتضي حكمًا عامًّا في جميع المسائل، لكن خُصِّصَتْ مسألة وعدل بها عن نظائرها، وصار لها حكم خاصٌّ بها؛ نظرًا لثبوت دليل أقوى قد خُصِّصَها وأخرجها عما يماثلها.

مثال ذلك: القياس أنه لا يجوز السَّكَمُ؛ لأنه عقد على معدوم وقت العقد، ولكن عُدِلَ عن هذا الحكم إلى الجواز؛ لدليل ثبت في السنة بجوازه، فترك القياس لهذا الخبر استحسانًا.

أنواعه:

ينقسم الاستحسان بحسب الدليل الذي يستند إليه إلى أنواع هي: ^(١)

١. **الاستحسان بالنص**؛ وهو العدول عن حكم القياس والقواعد العامة في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة.

مثاله: القياس أنه لا يجوز بيع العرايا؛ لأنه ربا، وهو داخل تحت النهي عن بيع المزانية، لكن ترك هذا القياس استحسانًا؛ لما ثبت في السنة أنه رُخِّصَ بيع العرايا؛ رفعًا للحرَج، ورعاية للحاجة ^(٢).

(١) انظر: أصول السرخسي (٢/٢٠٣)، التلويح على التوضيح لصدر الشريعة (٢/٨٢).

(٢) العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض، وقد اتفق الجمهور على جوازه. انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/٣٨٨-٣٩٠).

٢. **الاستحسان بالإجماع**: وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار.

مثاله: عقد الاستصناع^(١) فالقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم وقت العقد، لكنه أجاز بالإجماع؛ نظرًا لتعامل الأمة به من غير تكير، ومراعاة لحاجة الناس إليه.

٣. **الاستحسان بالقياس الخفي**: وهو العدول عن حكم القياس الجلي ظاهر العلة إلى حكم آخر بقياس خفي هو أدق من الأول وأقوى حجةً وأسدّ نظرًا.

مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر، فإن القياس الظاهر يقتضي نجاسته كسؤر سباع البهائم مثل الذئب، لكن عدل عن هذا القياس؛ لأن سباع الطير تشرب بمناقيرها التي لا رطوبة فيها، فهي كاللدجاج، بخلاف سباع البهائم التي يخالط لعابها النجس الماء فيلوّثه^(٢).

٤. **الاستحسان بالعرف**: وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظرًا لجريان العرف بذلك.

مثاله: من حلف لا يأكل اللحم فالأصل أنه يحنث بأكل السمك؛ لأنه لحم، كما سماه الله تعالى بقوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر: ١٢] لكنه لا يحنث استحسانًا؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق اللحم على السمك.

٥. **الاستحسان بالضرورة**: وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس؛ نظرًا للضرورة.

مثاله: الحكم بطهارة الآبار والحياض بنزع الماء منها حتى يذهب أثر النجاسة، ومقتضى القياس ألا تطهر بالنزع؛ لاختلاط الباقي بالنابع، وتنجس الدلو،

(١) وهو: أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له شيئًا نظير مبلغ معين بشروط معينة.

(٢) هذا عند الحنفية، أما عند الشافعية فسؤر سباع البهائم والطيور طاهر.

لكن ترك القياس لأجل الضرورة؛ لأنه لا يمكن غسل البئر مثل الثوب^(١).

❖ حجة الاستحسان:

الاستحسان بالمعنى السابق حجة، إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما الخلاف في تسمية ذلك استحساناً^(٢).

والاستحسان في الحقيقة لا يُعدّ دليلاً مستقلاً قائماً بذاته، بل يرجع إلى النص، أو القياس أو المصلحة ونحوها، وأكثر من استدلال به وتوسّع فيه الحنفية، ويُستدل لحجته ما يلي:

١. إنّ في الأخذ بالاستحسان ترك العسر إلى اليسر، وهو أصل في الدين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٢. وقوع الاستحسان في معاملات ثابتة بنصوص صحيحة كيبيع السلم والعرايا، وكذا وقوعه في عهد الصحابة والتابعين وكبار الأئمة المجتهدين.
٣. ما روي في الأثر عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء)^(٣).

❖ الاستحسان الباطل:

هناك معنى باطل للاستحسان وهو: ما يستحسنه المجتهد بعقله أي: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة.

(١) أصول الفقه للسلمي، ص: (١٩٥-١٩٦)، الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة، ص: (٣٨٣-٣٨٤)، الوجيز في أصول الفقه للزحيلي (٨٧-٨٨).

(٢) قال التاج السبكي: «الخلاف راجع إلى نفس التسمية، وأن المنكر عندنا إنما هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة، وأما استعمال لفظ الاستحسان فلنا نكره». رفع الحاجب للتاج السبكي (٤/ ٥٢٤).

(٣) رواه أحمد في المسند، وصححه الحاكم في المستدرک (٣/ ٧٨)، ووافقه الذهبي.

وممن أنكر وبالع في رد هذا النوع من الاستحسان الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، واشتهر عنه في ذلك قوله: «من استحسن فقد شرع»، وقوله: «إنما الاستحسان تلذُّذ»^(١).

التدريب

◀ يَبَيِّنُ الْمَعْنَى الصَّحِيحَ وَالْمَعْنَى الْبَاطِلَ لَلِاسْتِحْسَانِ.

◀ اذْكُرْ نَوْعَ الْاسْتِحْسَانِ فِيمَا يَلِي:

١. مقتضى القياس والقواعد العامة عدم جواز الوصية؛ لأنها تملك مضاف إلى زمن زوال الملكية بعد الموت، لكنها استثنيت لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيكَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
٢. لو قال شخص: «والله لا أدخل بيتاً»، فالقياس أنه يحث إذا دخل المسجد؛ لأنه يسمى بيتاً لغةً، والاستحسان أنه لا يحث.
٣. أجاز الفقهاء استحساناً استئجار الحمام من غير تحديد كمية الماء ومدة المكث فيه والقياس أن تكون محددة معلومة.
٤. أباح الفقهاء استحساناً النظر إلى العورة لغرض العلاج والتداوي.
٥. جرت عادة الناس أن يعطوا أجرة الإقامة في الفنادق مقابل خدمات غير محددة من أكل وشرب واستهلاك كهرباء، وهذا مخالف لقاعدة العلم بالعوضين - الثمن والمبيع - ومع ذلك فهو جائز.
٦. إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً، فإن عليه نصف عشر الدية؛ لقوله ﷺ: (فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ)^(٢)، مع أنَّ القياس أنه لا يجب على الضارب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته.

(١) إبطال الاستحسان للشافعي، ص: (٢٩). الرسالة للشافعي، ص: (٥٠٧).

(٢) نصب الراية للزيلعي (٤ / ٣٨١).

الدليل الثالث: المصلحة المرسلة

تعريفها:

المصلحة لغة: ضد المفسدة، ويراد بها جلبُ منفعة أو دفعُ مضرة. واصطلاحاً: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها^(١).

أقسام المصلحة:

أولاً: تنقسم المصلحة باعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

١. **مصلحة معتبرة شرعاً:** وهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية باعتبارها، مثل إقامة الصلاة، كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وإيجاب القصاص من القاتل عمداً، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].
٢. **مصلحة ملغاة شرعاً:** وهي المصلحة التي يراها العبد مصلحة ولكن الشرع ألغاه وأهدرها ولم يلتفت إليها، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر والربا.
- وهذا النوع من المصالح لا يختلف أهل العلم على أنه لا يجوز بناء الأحكام عليه.
٣. **مصلحة مرسلة:** وهي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها.

(١) ضوابط المصلحة للبوطي، ص: (٣٧).

وسُمّيت رسالة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد بها بالاعتبار أو بالإهدار، كما تسمى بالاستصلاح، والمناسب المرسل^(١).

✽ ومن أمثلتها:

١. تسجيل العقود في المحاكم والدوائر الحكومية؛ حفظاً للحقوق.
٢. إصدار عملة سائرة في كل بلد، وحمايتها من التزوير؛ لحاجة الناس الماسة إليها.
- ثانياً: تنقسم المصلحة من حيث أهميتها وقوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام هي:
١. **المصلحة الضرورية**؛ وتسمى درء المفسد، وهي التي يترتب على تفويتها تفويت شيء من الضروريات الخمس وهي: (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال)، وهذه أعلى المصالح. ومن أمثلتها:
 - إيجاب القصاص من القاتل العائد؛ لحفظ النفوس.
 - إيجاب قطع يد السارق؛ لحفظ أموال الناس.
 - إيجاب جلد الزاني والقاذف؛ لحفظ أعراض الناس والأنساب.
 - إيجاب جلد شارب الخمر؛ لحفظ العقول.
 - إيجاب قتل المرتد؛ لحفظ الدين.

٢. **المصلحة الحاجية**، وتسمى جلب المصالح، وهي التي يترتب على تفويتها تفويت حاجة لا ضرورة، مثل: مشروعية الإجارة والمضاربة ونحوها، وتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح؛ حرصاً على مصلحتها خوفاً فوات الكفء، فإنَّ ذلك لا ضرورة فيه، لكنه مُحْتَاجٌ إليه.

٣. **المصلحة التحسينية**، وتسمى التتميمات، وهي: ما ليس ضرورياً ولا

(١) انظر: مذكرة الشنقيطي، ص: (١٦٨ - ١٦٩)، معالم أصول الفقه للجيزاني، ص: (٢٣٧).

حاجياً، ولكنه من باب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ومن ذلك ما يتعلق بالتنظيف والتزين لتحسين المظاهر^(١).

❖ حجة المصلحة المرسلة:

اتفق العلماء على عدم حجة المصلحة المرسلة في العبادات؛ لأنها عبودية وليس للعقل مجال لإدراك المصلحة الجزئية لكل منها، وكذلك المقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث. واختلفوا فيما عدا ذلك على مذهبين: الأول: أنها حجة ومصدر من مصادر التشريع، وهو مذهب جمهور العلماء.

❖ ومن أدلتهم:

١. الآيات الدالة على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد واليسير عليهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
 ٢. عمل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بها في وقائع كثيرة مشتهرة^(٢).
 ٣. ولأن الغاية العظمى من التشريع تحقيق مصالح العباد في الدارين، وجميع ما جاء من الأحكام في الكتاب والسنة فهو لأجل ذلك، وجزئيات مصالح العباد لا تنتهي، فما سكت عنه الكتاب والسنة منها فالأصل أن تراعى فيه قواعد الإسلام في جلب المنافع ودفع المضار، فيؤخذ فيه ما يناسبه.
- الثاني: أنها ليست بحجة.

(١) الموافقات للشاطبي، ص: (٨-١٢)، معالم أصول الفقه للجيزاني، ص: (٢٣٨).

(٢) ومن الأمثلة على ذلك: تولية أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الخلافة من بعده، وتدوين عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للدواوين في عهده، واتخاذَه أيضاً داراً للسجن بمكة، وقتله الجماعة بالواحد، وإيقاعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وإبقاؤه الأراضي الزراعية التي فُتحت بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.

ووجه قولهم: أن الشريعة قد راعت مصالح العباد في تشريعها، فلا يتصور أن تكون أغفلت جانباً فيه مصلحة لهم، وفي القول بالمصلحة فتح للباب ليقول من شاء ما شاء^(١).

والحقيقة أن الذين خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنما خالفوا في عدّها دليلاً مستقلاً، أو في تقديمها على النصوص، لأن الواقع العملي يؤكد أن جميع فقهاء المذاهب أخذوا بالمصلحة المرسلة في كثير من الفروع، ومن تتبع المذاهب علم صحة ذلك^(٢)؛ لأن الجميع متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت، إلا أن الخلاف وقع في تسميته، فبعضهم يسميه مصلحة مرسلة، وبعضهم يسميه قياساً، أو عموماً، أو اجتهداً، أو عملاً بمقاصد الشريعة.

❦ شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

١. أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، مثل ما يتوهمه البعض من أن في التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام.

(١) تيسير أصول الفقه للجديد، ص: (٨٧).

(٢) وهذا ما أكدّه الإمام القرافي المالكي بقوله: «وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإن افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وفرقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب». شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص: (٣٩٤). وقال الزنجاني الشافعي: «ذهب الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كَلْبِ الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز». تحريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص: (٣٢٠).

وقال الغزالي: «وإذا فُسِّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة». المستصفي (١/١٤٣).

٢. ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع، وإلا فهي ملغاة.
٣. أن تكون المصلحة في مواضع الاجتهاد، لا في الأحكام التي لا تتغير، كأصول العقائد والعبادات، والحدود، والمقدرات الشرعية.
٤. ألا تعارض مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، فإن تعارضت المصالح قُدِّمَ أعظمها نفعاً، وأكثرها دفعا للمفسدة، ولذا تُقَدِّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة^(١).

التدريب

◀ بَيِّن فيما يلي نوع المصلحة، واعتبار الشرع لها أو عدمه:

١. مصلحة منع القتل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١].
٢. احتكار البضائع وقت الحاجة الماسة، ثم بيعها بأسعار باهظة.
٣. الغش في الامتحانات.
٤. إيجاب الزكاة، وفرض أدائها.
٥. تنظيم حركة المرور ووضع الإشارات في الطرق ومعاقبة من يخالفها.
٦. السماح بالفوائد الربوية؛ للنهوض بالاقتصاد.
٧. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة الطب.
٨. إجبار الولي على إرضاع الصغير وتربيته وشراء مطعمومه وملبوسه.
٩. اتخاذ الميكرفون لنداء الصلاة.

(١) معالم أصول الفقه للجيزاني، ص: (٢٣٨ - ٢٣٩)، أصول الفقه للسلمي، ص: (٢٠٩).

الدَّلِيلُ السَّابِعُ: العُرْفُ

❖ تعريفه:

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل.

❖ أنواعه:

ينقسم العرف إلى عدة أنواع منها:

١. **العرف القولي:** هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنىً مُعَيَّنًا غير المعنى الموضوع له في اللغة، كتعارفهم إطلاقَ لفظ الولد على الذكر دون الأنثى.

٢. **العرف العملي:** هو ما اعتاده الناس من أفعال، كالبيع بالتعاطي،^(١) وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.

❖ ومن أنواعه:

١. **العرف العام:** وهو ما تعارف عليه الناس في عامة البلاد، كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون الإنسان، والتعامل بالاستصناع.

٢. **العرف الخاص:** وهو ما شاع التعامل به في بلد أو فئة من الناس دون غيرهم، كإطلاق أهل العراق لفظ الدابة على الفرس، وكتعارف التجار على جعل الدفاتر حجة في إثبات الديون.

(١) بيع المعاوضة: هو البيع من غير إيجاب ولا قبول، مثل: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، من غير تكلم ولا إشارة، وجمهور العلماء - غير الشافعية - على جوازه، واختاره جماعة من الشافعية منهم البغوي والمتولي والنووي.

❖ ومن أنواعه:

١. **العرف الصحيح:** وهو ما لا يخالف دليلاً شرعياً، ولا يحلّ حراماً، ولا يحرم حلالاً، كالبيع بالمعاطاة.
٢. **العرف الفاسد:** وهو ما يخالف دليلاً شرعياً، أو يحلّ حراماً، أو يحرم حلالاً، كالعامل برّاء البنوك.

❖ حجّة العرف:

اعتبر العلماء العرف حجّة تثبت بها الأحكام إذا لم يوجد دليل شرعي آخر، وبنوا على ذلك قواعد منها: «العادة مُحَكِّمَةٌ» و«المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا» و«لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ». قال الإمام السيوطي: «اعلم أنّ اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تُعدّ كثرة»^(١).

❖ ومن أدلّة اعتباره:

١. قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]^(٢).
٢. حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ)^(٣).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: (٩٩).

(٢) قال السيوطي في تفسير هذه الآية في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل: «وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف».

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.

❖ شروطه:

١. أن يكون عامًّا أو غالبًا.
٢. ألا يكون مخالفًا للشرع، فإن كان مخالفًا للشرع فلا عبرة به، كالتعامل بالربا، وكشف العورات في الأعراس.
٣. ألا يكون معارضا بعرف آخر في نفس البلد.

❖ مجالات إعمال العرف:

١. ما ورد في الشرع من ألفاظ مطلقة ليس لها حد شرعي ولا لغوي فإنه يُرجع في تحديدها إلى العرف الصحيح.
- مثل وجوب النفقة على الزوج، فإنه ليس لها ضابط محدّد فيرجع فيها إلى العرف.
- وكذا السارق لا يُقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا ضابط له فيرجع فيه إلى عرف.
٢. تفسير ألفاظ الناس: فلو حلف شخص بأنه لا يأكل اللحم فإنه لا يحث بأكل السمك والدجاج؛ لأنه لا يُطلق عليهما في العرف لحم.

التدريب

◀ مثل لأعراف صحيحة، وأخرى فاسدة في بلدك.

◀ وضح نوع العرف فيما يلي: (قولي عملي - صحيح فاسد).

١. لو تباع اثنتان سيارة بخمسين ألفا ثم اختلفا، فقال البائع: خمسين ألف دولار، وقال المشتري: بل خمسين ألف درهم فالعبرة بعرف البلد الذي هما فيه.
٢. جرت عادة بعض الناس تقديم الأجرة قبل السكن في البيوت أو الفنادق.
٣. جرت العادة في بعض البلاد على سفور النساء واختلاطن بالرجال في المناسبات.
٤. إذا حلف إنسان بأنه لا يضع قدمه في دار فلان فإنه يحث بالدخول لا بوضع القدم.
٥. ما تعارفه الناس من أن ما يقدمه الخاطب أثناء الخطبة هدية، وليس جزءا من المهر.

الأدلة المختلف فيها الدليل الأول: قول الصحابي

❖ **تعريف الصحابي:** هو مَنْ لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك^(١). واشترط علماء الأصول طول صحبته وملازمته للنبي ﷺ؛ لأنه بهذا يكون له اجتهادٌ وفقهٌ.

والمراد بقول الصحابي: ما نُقل عن أحد من أصحاب النبي ﷺ من قول أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين. فمن أمثلة قول الصحابي قول علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)^(٢).

ومن أمثلة الفعل قول البخاري رحمه الله: (وأمّ ابن عباس وهو متيمّم)^(٣). ومن العمل الاجتهادي جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد.

❖ حجية قول الصحابي:

قول الصحابي له أقسام هي:

١. **قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:** كالغيبات والعبادات والتقديرات ونحوها. وحكمه في هذه الحالة أنه حجة؛ لأنه موقوف له حكم الرفع^(٤). ومن أمثلة ذلك: ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلّوا الكسوف بست ركوعاتٍ وأربع سجّاداتٍ، قال الإمام الشافعي: لو ثبت لقلتُ به.

(١) نخبة الفكر لابن حجر، ص: (٢١).

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٢٥).

(٣) فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٦).

(٤) قيد ذلك بعضهم بأن لا يُعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. انظر: شرح النخبة

للحافظ ابن حجر، ص: (٥٤٨).

وما رُوي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في الَّذِي يَأْتِي امرأته وهي حائض قال: (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)^(١)، فَإِنَّ الصَّوَابَ وقفه على ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٢- قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:

إذا اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل الاجتهاد فإن قول كل واحد منهم ليس بحجة؛ لأنه لو كان قول أحدهم حجة على غيره لما أمكن منهم هذا الخلاف. ومن أمثلة اختلاف الصحابة: اختلافهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واختلافهم في ميراث الإخوة مع الجد، هل يحجبهم الجد أم يشتركون.

٣- قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة:

وهذا من قبيل الإجماع السكوتي، وهو حجة عند أكثر العلماء، ومن ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قتل نفرا برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»، قال ابن حجر الهيثمي: ولم ينكر عليه مع شهرته^(٢).

٤- قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة:

كما رُوي عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ من جنى على سنّ فسّدها ففيها دية سنّ كاملة، ولم يُنقل فيه خلاف ولم ينتشر.

وقد اختلف العلماء في حجّيته على قولين:

القول الأول: أنه حجة، ونُسب إلى أبي حنيفة ومالك في المشهور والشافعي في القديم، وأحمد في رواية^(٣).

✽ أدلتهم:

١. قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

(١) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان.

(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر (٤/١٨).

(٣) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، ص: (١٠)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، ص: (١١٥-١١٦)، إعلام الموقعين لابن القيم (١/٣٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/٥٥-٦٠).

الْمُنْكَرِ ﴿آل عمران: ١١٠﴾ فهذا خطاب للصحابه بأن ما يأمرون به معروف، والمعروف يجب قبوله.

٢. ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ^(١) فهذه شهادة لهم بالفضل على من سواهم، وذلك يقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ^(٢).

٣. ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره؛ لمشاهدته الوحي وقربه من الرسول ﷺ، ويحتمل أن يكون قوله نقلاً عن النبي ﷺ فيقدم على الرأي المحض.

❖ **القول الثاني:** ذهب إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، وعليه مذهب الشافعية في الجديد، وأحمد في رواية، والظاهرية ^(٣).

❖ أدلتهم:

١. قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] فالآية أمرت بالاعتبار والقياس والاجتهاد فيما لا نص فيه، والأخذ بقول الصحابي تقليد.

٢. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] فالله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله ﷺ، والصحابي من أهل الاجتهاد، والمجتهد غير معصوم، فيجوز عليه الخطأ والسهو، ولذا رجع بعض الصحابة عن فتواه مما يدل على عدم حجية أقولهم.

٣. حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المشهور لما بعثه الرسول ﷺ إلى اليمن وفيه قال ﷺ: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) ومما استدلوا به حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي). أخرجه أبو داود والترمذي، وهو صحيح.

(٣) ظاهر نصوص الإمام الشافعي في الرسالة وغيرها على أنه يأخذ بقول الصحابي عند عدم النص.

آلو^(١). فمعاذ اكتفى بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يضيف أقوال الصحابة، وأقره الرسول ﷺ على ذلك.

٤. ما أثر عن التابعين من مخالفة آحاد الصحابة، ولو كان قول الصحابي حجة لما صحت مخالفة التابعي له، وإذا جاز ذلك للتابعي جاز لغيره^(٢).

التدريب

◀ بين صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يلي مع ذكر نوعه:

١. ورد أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يسوي في العطاء بين الناس، وخالفه في ذلك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكان يعطي صاحب السبق في الإسلام أكثر من غيره.
٢. رُوي عن علي وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الإمام أحق من صلى على الجنازة، ولم يُنقل فيه خلاف ولم ينتشر.
٣. عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «يتم لكل صلاة وإن لم يحدث» قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر الهيتمي: ولا يعرف له مخالف من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
٤. رُوي عن عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قوله: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم». وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله».
٥. رُوي عن حذيفة وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنهما قالَا: «إذا وضعتها - أي الزكاة - في صنف واحد أجزأك»، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
٦. قضاء الصحابة في النعمة ببذنة إذا اصطادها المحرم، وقضاؤهم في الغزال بعنز.



(١) أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الخطيب البغدادي قائلاً: «على أن أهل العلم قد قبلوه واحتجوا به فوقنا بذلك على صحته عندهم». الفقيه والمتفقه (١/ ١٨٩).

(٢) أصول الفقه للسلمي، ص: (١٨٧).

الدليل الخامس: شرع من قبلنا

الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وفي الحديث (الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد)^(١).

فشرائع الأنبياء متفقة في أصول الدين وأمور العقيدة، وأصول الفضائل والأخلاق كحفظ الأمانات وتحري الصدق، والبعد عن الفواحش والرذائل، وإقامة العدل، وقد قال ﷺ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)^(٢)، ولكنها مختلفة في تفاصيل العبادات وجزئيات الأحكام، والشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة

❖ **تعريف شرع من قبلنا:** هي الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وقصّها علينا القرآن الكريم أو السنة المطهرة.

والطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن أو السنة، ولا عبرة بكتب اليهود والنصارى اليوم؛ لأنها محرّفة.

❖ **أنواع شرع من قبلنا وحجّيته:**

شرع من قبلنا على ثلاثة أنواع:

١. **ما ثبت في شرعنا ما يؤيده ويقرره:** فهذا شرع لنا بلا خلاف. مثل: فرض الصيام، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

٢. **ما ورد في شرعنا ما ينسخه ويبطله:** وهذا ليس شرعاً لنا بلا خلاف، مثل: الغنائم، فإنها كانت محرّمة على من قبلنا فنسخها شرعنا بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٩] وقوله ﷺ: (وأحلت لي المغنم ولم تحل لأحد قبلي)^(٣).

(١) أخرجه البخاري، وأولاد العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة، وأبوهم واحد، قال ابن حجر: «أي: أن أصل دينهم واحد، وشرائعهم مختلفة» فتح الباري لابن حجر (٦/ ٤٨٠).

(٢) رواه أحمد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٨): رجاله رجال الصحيح.

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.

٣. ما نُقل إلينا ولم يقترن بما يدل على بقاء الحكم أو إلغائه بالنسبة لنا:

مثل: جواز الجعالة^(١) لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. وهذا النوع اختلف في حجيته بالنسبة لنا على قولين:

القول الأول: يرى حجيته، وأنه كجزء من شريعتنا، وإليه ذهب جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في المشهور من مذهبه. واستدلوا بما يلي:

١. قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أَقْتَدَ﴾ [الأنعام: ٩٠] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣] فقد أمر الله نبيه ﷺ بالافتداء بالأنبياء قبله، واتباع ملتهم، فيكون متعبدا بشرع من قبله، وأمر الرسول ﷺ أمر لأمره.

٢. قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الشورى: ١٣] فهذه الآية تدل على أن شرع نبينا محمد ﷺ مثل شرع غيره من الأنبياء.

القول الثاني: يرى عدم حجيته، وأنه ليس بشرع لنا، وهو الراجح من مذهب الشافعية^(٢).
ومن أدلتهم:

١. قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٦٧] فإنه يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره.

٢. الشرائع السابقة خاصة لأقوامها، ومؤقتة بزمن محدد، وصالحة لحال معين، أما شريعتنا فعامّة ومؤبّدة، وصالحة لجميع الأحوال، قال ﷺ: (وكان النبي

(١) الجعالة شرعا: أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا، كأن يقول: من وجد ضالتي فله كذا.

(٢) قال الإمام الإسني: «والمسألة فيها قولان أصحهما وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب أنه ليس بشرع». المهمات للإسني (١٣٣/٦).

يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً^(١).
 ٣. ولأنه لو كانت شرائع من قبلنا حجة لأمر رسول الله ﷺ بالرجوع إلى كتبهم وأخبارهم، ولما أمر بانتظار الوحي من الله.

ومن أمثلة هذا النوع المختلف فيه:

١. الاستدلال على جواز الوكالة بقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ [الكهف: ١٩].
٢. الاستدلال على جواز الضمان بقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

التدريب

◀ ما المراد بشرع من قبلنا ؟ وما النوع الذي وقع الخلاف في حجته ؟

◀ بين ما أقره شرعنا وما نسخه من الأحكام التالية الواردة في الشرائع السابقة.

١. قطع موضع النجاسة في الثوب^(٢).
٢. مشروعية الختان للذكر والأنثى.
٣. تحريم كل ذي ظفر، وتحريم شحوم البقر والغنم على اليهود كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦].
٤. مشروعية القصاص في شريعة اليهود، كما في قوله تعالى: ﴿وَكُنِينَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
٥. تشريع الأضحية الذي كان سنة إبراهيم عليه السلام.
٦. مشروعية صيام عاشوراء عند اليهود.
٧. سجود التحية والتعظيم لغير الله، كما في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠].

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) فعن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَاب ثَوْبَ أَحَدِهِم الْبَوْلَ قَرَضَهُ ،
 أي: قطع الموضع الذي أصابه البول من ثيابه. صحيح البخاري.

الدليل الثاني: الاستصحاب

تعريفه:

لغة: طلب الصحبة.

واصطلاحاً: جعل الشيء الثابت في الماضي باقياً على حاله، حتى يقوم الدليل على انتقاله.

مثاله: إذا توضأ شخص ثم شك في انتقاض وضوئه فإنه يستصحب الحكم السابق وهو كونه طاهراً حتى يثبت خلافه.

أنواع الاستصحاب: (١)

ينقسم الاستصحاب إلى أقسام هي:

١- استصحاب البراءة الأصلية:

فالأصل براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية، والحقوق المالية حتى يرد دليل شرعي على ثبوت ذلك، مثاله: عدم وجوب صوم رجب، وصلاة سادسة، وبراءة ذمة الإنسان من الديون.

٢- استصحاب الإباحة الأصلية:

ف«الأصل في الأشياء النافعة الإباحة» على الصحيح. بدليل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، كما أن «الأصل في الأشياء الضارة الحرمة»، فكل حيوان أو نبات حلال إلا إذا ورد النص بالتحريم كالحمير الأهلية، وكل معاملة من بيع ونحوه حلال إلا ما استثناه الشرع كالربا.

(١) شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٨٤)، الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي، ص: (١١٣-١١٤).

وكذلك «الأصل في الأشياء الطهارة»، فمن ادعى نجاسة عين من الأعيان طُوب بالدليل.

٣- استصحاب ما دلّ الشرع أو العقل على ثبوته ولم يقر دليل على تغييره؛
كاستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاً، فلو ادّعت الزوجة الطلاق فالأصل عدمه، وعليها البيّنة.

٤- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض؛

كاستصحاب النص حتى يأتي ناسخه، واستصحاب العموم حتى يأتي مخصّصه.

٥- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف؛

كاستدلال من يقول بصحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته بأنّ الإجماع منعقد على صحة صلاة مَنْ تيمّم لفقد الماء، فيستصحب هذا الإجماع إلى أن يدلّ دليل على أنّ رؤية الماء أثناء الصلاة مبطلّة.

❁ حجية الاستصحاب:

جمهور العلماء على حجية الاستصحاب، إلا في مسائل جزئية وقع فيها الخلاف^(١).

ومن الأدلة على حجّيته:

١. قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فقد بينت الآية أنّ ما اكتسب من الأموال قبل تحرّيم الربا فهو حلال؛ بناءً على البراءة الأصلية.

٢. قوله ﷺ في الرجل الذي يُخيل إليه أنه أحدث في صلاته: (لا يُصَرِّفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)^(٢)، وهذا عمل بالاستصحاب؛ لأنّ النبي ﷺ

(١) وأكثر من خالف في حجية الاستصحاب الحنفية، وهذا فيما عدا النوع الأخير (استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف) فأكثر العلماء على أنه ليس بحجة.

(٢) متفق عليه.

- حكم باستصحاب حكم الوضوء حتى يثبت انتقاضه يقينا.
٣. حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ ^(١)، وهذا عمل بالاستصحاب؛ لأنَّ الأصل براءة ذمة المدَّعى عليه حتى يثبت شغلها بالبيِّنة الصحيحة.

❦ قواعد مبنية على الاستصحاب:

١. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٢. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة.
٣. الأصل في الأشياء الضارة التحريم.
٤. اليقين لا يزول بالشك.
٥. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق.
٦. الأصل في الذبائح التحريم.

التدريب

◀ بيِّن نوع الاستصحاب فيما يلي:

١. بقاء وضوء من توضأ إذا شك في الحدث.
٢. إذا ادَّعى الشريك أن المال لم ينتج ربحاً قبلت دعواه، لأنَّ الأصل عدم الربح.
٣. عدم وجوب صلاة الوتر.
٤. إذا أصيب ثوب الإنسان بماء لا يدري أهو نجس أم طاهر حكم بطهارته.
٥. استصحاب حياة المفقود، فيعامل معاملة الأحياء حتى يأتي الدليل على انتفائها.
٦. لو ادَّعى رجل ثبوت امرأة تزوجها على أنها بكر لم يقبل إلا ببيِّنة.
٧. بقاء الملك في المبيع مع وجود الشك في زواله.
٨. من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، ولم يتبيَّن له الأمر صحَّ صومه.

(١) متفق عليه.

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: سُدُّ الذَّرَائِعِ

❖ تعريفه:

الذَّرَائِعُ جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كان مصلحة أم مفسدة.

وسدُّ الذَّرَائِعِ: منع الوسائل المؤدية إلى المفسد.

والوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصد، فإن كانت الوسيلة مفضية إلى مصلحة أخذت حكمها من الوجوب أو الإباحة، وإن كانت مفضية إلى مفسدة أخذت حكمها من حيث التحريم أو الكراهة، ولذا قال العلماء: «الوسائل لها حكم المقاصد»، و«الأمر بمقاصدها».

❖ حجية سدِّ الذَّرَائِعِ:

الأفعال والأقوال المؤدية إلى المفسد على أنواع: ^(١)

النوع الأول: ما يؤدي إلى المفسد قطعاً كشرب الخمر المؤدي إلى السكر، والزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا لا خلاف بين العلماء في منعه.

النوع الثاني: ما وُضع في الأصل للوصول إلى المباح، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقليلًا، ومصلحته أرجح من مفسدته، وهذا لا خلاف في مشروعيته، ولا يُمنع بحجة ما قد يترتب عليه من مفسد، كالنظر إلى المخطوبة، وزراعة العنب.

النوع الثالث: ما وُضع في الأصل للوصول إلى المباح لكن قُصد به التوسل إلى المفسدة، كالتوسل بالبيع إلى الربا، أو يؤدي إليها غالباً، ومفسدته أرجح من مصلحته

(١) انظر: الموافقات للشاطبي (٢/ ٣٥٨) وما بعدها، أصول الفقه للسلمي، ص: (٢١١-٢١٢).

كبيع السلاح في أوقات الفتن، وبيع العنب لمن عُرف عنه الاحتراف بعصره خمراً. وقد اختلف العلماء في هذا النوع أيمنع سداً للذريعة إلى المفسدة أم لا؟ فذهب المالكية والحنابلة إلى الأخذ بمبدأ سد الذرائع، وعدّوه دليلاً معتبراً من أدلة الأحكام تُبنى عليه الأحكام.

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فقد نهى الله عن سب آلهة المشركين مع كونه أمراً واجباً؛ لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى على وجه المقابلة. واستدلوا كذلك بعمل النبي ﷺ بسدّ الذرائع، ومن ذلك كفه عن قتل المنافقين في عهده؛ لكي لا يُتخذ ذلك ذريعة إلى القول بأنّ محمداً يقتل أصحابه^(١). وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية والظاهرية فلم يصرحوا بالأخذ بمبدأ سدّ الذرائع كدليل؛ نظراً للإباحة الأصلية إلا أن يرد بمنعها نص أو إجماع أو قياس.

التدريب

◀ بين حكم العمل بمبدأ سدّ الذرائع فيما يلي:

١. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية سداً للذريعة إلى الزنا.
٢. تحريم حفر البئر في مكان يقع فيه المارّ حتماً.
٣. منع تأجير العقار لمن يتخذه مَحَلًّا للقمار.
٤. منع النظر إلى المرأة المشهود عليها؛ درءاً للفتنة.
٥. منع بيع العنب؛ سداً للذريعة صناعة الخمر.

(١) والحديث في ذلك متفق عليه.

الفصل الثاني

الأحكام الشرعية

الكلام عن الأحكام الشرعية ينقسم إلى أربعة مباحث : الحكم ، والحاكم ، والمحكوم فيه ، والمحكوم عليه .

المبحث الأول - الحكم

تعريفه ، أقسامه ، أنواع كل قسم .

تعريف الحكم :

الحكم في اللغة : المنع ، وعند الأصوليين ، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وعند الفقهاء : هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل ، كالوجوب والحرمة والإباحة^(١) .

فقوله تعالى : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة : ١/٥] ، هذا النص المتعلق بإيفاء العقود هو نفسه الحكم الشرعي عند الأصوليين ، وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء بالعقود هو الحكم عند الفقهاء . ومثله ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٢٢/١٧] ، المتعلق بالإنهي عن الزنا هو الحكم عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه وهو حرمة الزنا هو الحكم عند الفقهاء . ومثله : ﴿ لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [الحجرات : ١١/٤٩] .

(١) التقرير والتحجير : ٧٨/٢ ، حاشية البناني على جمع الجوامع : ٤٠/٨ ، شرح العضد : ٢٢٢/١ ، للدخل إلى مذهب أحمد : ص ٥٨ ، إرشاد الفحول : ص ٦ .

وقوله عز وجل : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩/٢] ، المتعلق بأخذ الزوج بدلاً مالياً من زوجته مقابل تطليقها هو الحكم عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هو الحكم عند الفقهاء . ومثله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢/٥] ، النص نفسه هو الحكم الأصولي ، وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من الإحرام هو الحكم الفقهي .

وخطاب الله تعالى أو كلامه يشمل المباشر منه وهو القرآن ، أو بواسطة وهو السنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة ، فكل واحد من هذه الأدلة هو الحكم الشرعي عند الأصوليين .

فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث القتال » هذا النص نفسه المتعلق بوضع القتل مانعاً من الميراث هو الحكم الوضعي عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه أو الذي يقتضيه وهو الحرمان من الإرث هو الحكم عند الفقهاء . ومثله « لا يقبل الله صلاة من غير طهور » يتضمن جعل الطهارة شرطاً للصلاة .

والمراد بالاقتضاء : الطلب ، سواء أكان طلب الفعل أم طلب الترك ، وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازم فهو الندب ، وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم ، وإلا فهو الكراهة .

والمراد بالتخيير : الإباحة ، وهو استواء الفعل والترك . فتدخل الأحكام الخمسة التكليفية في التعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير .

والمراد بالوضع : جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة . وهذه أنواع الحكم الوضعي . فقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [الإسراء : ٧٨/١٧] ، هذا الكلام نفسه من الشارع هو الحكم الأصولي الوضعي ، وجعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة وشغل ذممة المكلف بها هو الحكم الفقهي .

وهكذا يتبين أن الحكم الأصولي هو النص الشرعي نفسه ، والحكم الفقهي هو الأثر الذي يقتضيه النص الشرعي . والمعنى الأول هو الموافق لاصطلاح رجال القضاء المعاصر ، فهم يقصدون بالحكم نفس النص الصادر من القاضي ، لذا يقولون : منطق الحكم كذا ، لكن اصطلاح الفقهاء أولى وأوضح للترقية بين النص ذاته وأثره ، أو بين الحكم الشرعي ودليله الذي يدل عليه من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس .

أقسام الحكم :

ينقسم الحكم الشرعي كما تبين من تعريفه قسمين : الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ لأن كلام الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو التخيير ، أو على سبيل الوضع ، فإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير ، فهو الحكم التكليفي ، وإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الوضع ، فهو الحكم الوضعي .

الحكم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه ، مثال طلب الفعل : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] ، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ١٨٣/٢] ، ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ١٠٣/٩] ، ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧/٣] ، ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة : ١/٥] .

ومثال طلب الكف عن الفعل : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام : ١٥١/٦] ، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ ﴾ [المائدة : ٣/٥] ، ﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [الحجرات : ١١/٤٩] ، ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢/١٧] .

ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والترك : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [النساء : ١٠١/٤] ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء : ١٠١/٤] ، ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢/٥] ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة : ١٠/٦٢] .

وسمي هذا النوع حكماً تكليفاً ؛ لأنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل ،
أو التخيير بينهما ، لكن إطلاق التكليف على المباح هو من باب التغليب .

والحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه
ونحو ذلك مما سيأتي . مثال السبب قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾
[البقرة : ١٨٥/٢] ، فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم ، وقوله سبحانه : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء : ٧٨/١٧] ، فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر ، وهذا
غير مقدور للمكلف .

وقوله عز وجل : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة : ٦/٥] ، فإرادة إقامة الصلاة سبب في إيجاب الوضوء .
وقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ١٣٨/٥] ، جعل
السرقه سبباً في إيجاب قطع يد السارق ، وقول الرسول ﷺ : « من قتل قتيلاً فله
سلبه » أي ما يكون مع القتل من مال وسلاح ومتاع ، جعل قتل القتل سبباً في
استحقاق سلبه . وكل هذه أسباب مقدورة للمكلف .

ومثال الشرط قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧/٣] ، جعل الاستطاعة المالية والبدنية شرطاً لإيجاب الحج ،
وقوله ﷺ : « لا يقبل الله صلاة من غير طهور » ، جعل الطهارة شرطاً في قبول
الصلاة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » جعل
حضور الولي والشاهدين شرطاً في صحة عقد الزواج . وكل هذه شروط مقدورة
للمكلف ، وهناك شرط غير مقدور للمكلف ، مثل بلوغ الحلم لانتهاء الولاية على
النفس ، وبلوغ الرشد لنفاذ العقود .

ومثال المانع المقدور للمكلف : قوله ﷺ : « لا يرث القاتل » جعل الشارع القتل
مانعاً من الميراث ، وهو مقدور للمكلف . وغير المقدور كالأبوة فإنها عند الجمهور غير
المالكية مانعة من القصاص بقتل الأب ابنه .

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : هناك فرق بين القسمين من وجوه

ثلاثة :

الأول - يقصد بالحكم التكليفي طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين الفعل والترك . أما الحكم الوضعي فلا يقصد به التكليف أو التخيير ، وإنما يقصد به ارتباط أمر بآخر يجعله سبباً له أو شرطاً له أو مانعاً منه .

الثاني : المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين في الحكم التكليفي : أنه لا بد من أن يكون مقدوراً للمكلف وفي الاستطاعة أن يفعله أو يكف عنه حتى يتأتى الامتثال . أما الحكم الوضعي فقد يكون مقدوراً للمكلف وقد لا يكون مقدوراً له ، كما تقدم ، وكما في الأمثلة التالية ، فهناك سبب مقدور للمكلف كصيغ العقود والتصرفات وارتكاب الجرائم ، فإن الصيغ سبب لترتب أحكامها ، والجرائم سبب لاستحقاق عقوباتها . وغير المقدور للمكلف كالقربة سبب للإرث ، والإرث سبب للملك ، ودلوك الشمس (أي الزوال في منتصف النهار) سبب لوجوب الصلاة ، وهما غير مقدورين للمكلف .

والشرط المقدور للمكلف : إحضار شاهدين في عقد الزواج ، والطهارة شرط لصحة الصلاة . وغير المقدور للمكلف : بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس ، وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات ، وهما غير مقدورين للمكلف .

والمانع المقدور للمكلف : قتل الوارث مورثه ، وغير المقدور للمكلف : الأبوة ، فإنها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند الجمهور ، وكون الموصى له وارثاً ، وهما غير مقدورين للمكلف .

الثالث - لا يتعلق الحكم التكليفي إلا بالمكلف ، وأما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالإنسان ، سواء أكان مكلفاً أم غيره كالصبي والمجنون ، فإنه يثبت في حقها الحكم الوضعي ، كصحة بيع الصبي ، وضمان متلفاتها وثبوت الدين في ذمتها .

أنواع الحكم :

ينقسم كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى أنواع .

أنواع الحكم التكليفي : ينقسم الحكم التكليفي إلى أنواع خمسة ؛ لأن طلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازم فهو الندب ، وطلب الكف عن الفعل إن كان جازماً فهو التحريم ، وإن كان غير جازم فهو الكراهة . وإن كان الخطاب على وجه التخيير فهو الإباحة .

فتكون الأمور المطلوب فعلها أو تركها أو التخيير فيها خمسة أنواع ، ويكون الفعل المطلوب إيقاعه قسمين : الواجب والمندوب ، والمطلوب تركه قسمين : الحرام والمكروه ، والفعل المخير فيه بين الفعل والترك هو قسم واحد ، وهو المباح .

١ - الواجب

تعريفه ، أقسامه ، أحكامه .

تعريف الواجب :

الواجب : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً ، بأن اقترن طلبه بما يدل على الإلزام به . إما من صيغة الطلب نفسها ، أو من قرينة خارجية كترتيب العقوبة على الترك ، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والوفاء بالعقود .

واستفادة الوجوب إما من صيغة الأمر ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] ، وإما من المصدر النائب عن فعله مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ ﴾ [محمد : ٤٧/٤] ، أو من الفعل المضارع المقترن باللام ، كقوله تعالى : ﴿ لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق : ٧/٦٥] ، أو من مادة الفعل ، مثل قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ١٨٣/٢] ، أو من أساليب

أخرى تدل في اللغة العربية على الطلب الجازم ، مثل (على) في قوله تعالى : ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧/٣] .

وحكم الواجب :

أنه يلزم الإتيان به ، ويثاب فاعله ، ويعاقب تاركه ، ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي .

ولا فرق عند الجمهور بين الفرض والواجب ، فهما مترادفان ، فكل منهما يستوجب تاركه الذم شرعاً . وأما الحنفية فقالوا : الفرض : ما ثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه ، كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم ، أو بالسنة المتواترة أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة . والواجب : ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة ، كصدقة الفطر وصلاة الوتر والعيدين ، ثبت كل منها بدليل ظني وهو خبر الواحد^(١) .

وإقامة الصلاة فرض لطلبها بدليل قطعي هو قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] ، وقراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة : لأنها طلبت بدليل ظني هو حديث « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » لكن الواقع أن هذا الحديث متواتر .

أقسام الواجب :

لِلوَأَجِبِ تَقْسِيمَاتٌ أَرْبَعَةٌ مِنْ نَوَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ .

التقسيم الأول - باعتبار وقت الأداء :

ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مطلق وواجب مقيد أو مؤقت^(٢) .

الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حتماً ، ولم يعين وقتاً لأدائه ، كال كفارات ومنها كفارة اليمين ، ليس لفعلها وقت معين ، فإما أن يكفر الحانث عقب الحنث مباشرة أو بعد ذلك ، وكالحج : واجب على المستطيع دون تحديد عام معين .

(١) التقرير والتحرير : ٨٠/٢ ، كشف الأسرار : ٦٢٠/١ .

(٢) التلويح على التوضيح : ٢٠٢/١ .

والواجب المقيد أو المؤقت : هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معين ، كالصلوات الخمس ، لكل صلاة منها وقت معين ، وكصوم رمضان .

ويترتب على هذا التقسيم : أن الواجب المقيد يأثم المكلف بتأخيره عن وقته بغير عذر ، والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين ، يجوز أدائه في أي وقت شاء .

وينقسم الواجب المقيد عند الحنفية إلى ثلاثة أنواع :

١ - الواجب الموسع : وهو الذي يكون وقته الذي أقره الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه ، مثل وقت صلاة الظهر .

٢ - الواجب المضيق : هو الذي يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه ، مثل شهر رمضان ، ويسمى هذا الوقت معياراً .

٣ - الواجب ذو الشبهين : هو الذي لا يسع وقته غيره من جهة ، ويسع غيره من جهة أخرى ، كالحج لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره ، من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجاً واحداً ، ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره في قوله تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة : ١٩٧/٢] ، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

ويترتب على هذا التقسيم : أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية ، فمن صلى في وقت الظهر أربع ركعات ، إن نوى الظهر كان أداء له ، وإذا لم ينو ، لم تكن صلاته أداء له . وإن صلاه بعد الوقت المعين كان قضاء ، وإن أداه مرة أخرى في الوقت بسبب أداء سابق مختل فهو إعادة .

والواجب المضيق وقته : لا يجب على المكلف عند الحنفية تعيينه بالنية ، فمن نوى في شهر رمضان الصيام مطلقاً ، انصرف صيامه إلى الصيام المفروض ، ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعاً ، وإنما يقع عن المفروض ؛ لأن الشهر لا يسع صوماً غيره .

التقسيم الثاني - باعتبار تقديره من الشارع :

ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد .

فالواجب المحدد : هو ما عيّن له الشارع مقداراً معلوماً ، فلا تبرأ ذمة المكلف منه إلا إذا أذاه على الصفة التي عينها الشارع ، كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية وأثمان المشتريات ، فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء الصلوات بعدد ركعاتها ، وأداء الزكاة بمقدارها ، وثن المبيع ودين المقرض وأجر المستأجر بالحدود المتفق عليها ، وكذا النذر بالشيء الملزم به .

وحكم الواجب المحدد : أنه يجب ديناً في الذمة ، وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضا ، ولا تبرأ ذمة المكلف به إلا بأدائه على الوجه المحدد شرعاً .

والواجب غير المحدد : هو ما لم يعين الشارع مقداره ، بل طلبه من المكلف بغير تحديد ، كالإنفاق في سبيل الله ، والتعاون على البر ، والتصدق على الفقراء إذا وجب بالنذر ، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف ، وغير ذلك من الواجبات غير المحددة شرعاً ؛ لأن المقصود بها سد الحاجة ، وذلك يختلف بحسب الأحوال . ومنه نفقة الزوجة ونفقة القريب لا تجب إلا بالقضاء أو الرضا ، ولا يطالب بها إلا بعد ذلك .

وحكم الواجب غير المحدد : أنه لا يثبت ديناً في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا ؛ لأن الذمة لا تشغل إلا بشيء معين ، حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته منه .

ويترتب على هذه القسمة : أن الواجب المحدد يجب ديناً في الذمة ، وتجاوز المقاضاة به ، وأن الواجب غير المحدد لا يجب ديناً في الذمة ، ولا تجوز المقاضاة به ؛ لأن الذمة لا تشغل إلا بيمين ، والمقاضاة لا تكون إلا بشيء معين المقدار ، ولا تجوز المطالبة به عند الحنفية إلا بعد القضاء أو الرضا .

التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله :

ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب كفائي .

الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر ، كالصلاة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كالخمر والزنا والميسر والربا . وحكمه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض .

لكن تجوز النيابة في الحج عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله على القرية المالية غالباً في الإنفاق في الأسفار .

والواجب الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين ، لا من كل فرد على حدة ، فإذا قام به البعض ، سقط الإثم عن الباقين ، كتعلم الصناعات المختلفة وبناء المشافي ، والصلاة على الجنائز وردّ السلام ، والجهاد ، والقضاء والإفتاء ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ، وأداء الشهادة .

وحكمه : أنه يجب على المجموع ، فإذا فعله واحد من المكلفين سقط الإثم والطلب عن الباقين . وإذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي ، صار واجباً عينياً ، فلو شاهد الغريق شخص يحسن السباحة ، وجب عليه إنقاذه ، ولو لم ير الحادثة إلا شخص واحد دعي للشهادة ، وجب عليه أدائها ، ولو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد ، تعيّن للإسعاف والاستطباب .

التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به :

ينقسم الواجب باعتبار تعين المطلوب بذاته وعدم تعينه ، إلى واجب معين وواجب مخير .

والواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره ، كالصلاة والصيام ورد المغصوب وأداء الثمن والأجرة . وحكمه : أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه .

والواجب الخير أو المبهم : هو ما طلبه الشارع مبهماً ضمن أمور معينة ، كأحد خصال الكفارة ، فإن الواجب فيها على الموسر أحد ثلاثة أمور على التخيير ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، أما المعسر الذي لم يجد شيئاً من تلك الخصال وعجز عنها ، فيصوم ثلاثة أيام .

وحكمه : أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع فيها ، فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب .

٢ - المندوب

تعريفه ، أنواعه .

تعريف المندوب :

الندب لغة : هو الدعاء إلى الفعل ، والمندوب عبد الأصوليين : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم . ويعرف الندب أو السنة : إما بصيغة الطلب نفسها فتدل على عدم الإلزام ، مثل قوله ﷺ : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أو بصيغة الأمر مع قرينة تدل على عدم الوجوب ، مثل قوله تعالى في الأمر بكتابة الدين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢/٢] ، فإنه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة منصوصة في الآية التي تليها : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢/٢] ، أي للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين . ومثل قوله تعالى في مكاتبة الأرقاء : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور : ٢٣/٢٤] ، فإنه صرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن المالك حر التصرف في ملكه .

أنواع المندوب :

ينقسم المندوب إلى ثلاثة أنواع ^(١) :

(١) مرآة الأصول : ٣٩٢/٢ ، كشف الأسرار : ٦٣٠/١ .

١ - مندوب فعله على وجه التأكيد : وهو الفعل الذي لا يستحق تاركة العقاب ، ولكن يستحق اللوم والعتاب ، مثل الأفعال المكلمة للواجبات الدينية ، كالصلاة جماعة ، والأذان والإقامة ، وكل ما كان عليه الرسول ﷺ ولم يتركه إلا نادراً ، كالمضضة والاستنشاق في الوضوء ، وقراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة . ويسمى هذا النوع : السنة المؤكدة أو سنة الهدى .

وحكمه : أن فاعله يستحق الثواب ، وتاركة لا يستحق العقاب ، ولكن يستحق اللوم والعتاب . وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة ، واتفق أهل البلدة على تركه ، وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة .

٢ - مندوب مشروع فعله : وفاعله يثاب وتاركة لا يعاقب ولا يعاتب ، كالأمور التي لم يواظب عليها الرسول ﷺ ، وإنما فعلها مرة أو أكثر ، وتركها ، مثل صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء ، وجميع التطوعات كصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . ويسمى هذا القسم فضلاً أو مستحباً .

وحكمه : أن فاعله يستحق الثواب ، وتاركة لا يستحق اللوم والعتاب .

٣ - مندوب زائد : أي من الكماليات لمكلف ، كالأمور العادية التي فعلها الرسول ﷺ بحسب العادة ، كالإقتداء بأكل الرسول ﷺ وشربه واتباعه في مشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك . ويسمى هذا القسم سنة زوائد وأدباً وفضيلة ؛ لأن هذه الأمور ليست تشريعاً .

وحكمه : أن تاركة لا يستحق اللوم والعتاب ، وفاعله يستحق الثواب إذا قصد بفعله التأسى والاقتران بالرسول ﷺ .

٣ - الحرام

تعريفه ، أنواعه .

تعريف الحرام :

الحرام : ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام^(١) . ويعرف طلب الترك على سبيل الحتم إما بمادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ٢٧٥/٢] ، وقوله سبحانه : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣/٤] ، وقوله عز وجل : ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ [النساء : ١٩/٤] . وقوله ﷺ : « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ » ، أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتمية ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢/١٧] ، ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ [الإسراء : ٣١/١٧] ، أو بالأمر بالاجتناب مقترناً بما يدل على الحتمية ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج : ٣٠/٢٢] ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠/٥] ، أو بترتيب العقوبة على الفعل ، مثل قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ، إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء : ١٠/٤] ، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ١٣٨/٥] ، ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور : ٤/٢٤] .

أنواعه :

ينقسم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته ، وحرام لغيره^(٢) .

(١) النهاج مع شرح الإسنوي : ٦٠/١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦٢ .

(٢) التلويح على التوضيح : ١٢٦/٢ ، مرآة الأصول : ٣٩٤/٢ .

الحرام لذاته : هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداءً ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته ، كالزنا والسرقه والصلاة بغير طهارة ، وأكل الميتة ، ونكاح المحارم ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل أموال الناس بالباطل . وحكمه : أنه غير مشروع أصلاً ، وإذا فعله المكلف وقع باطلاً ، فالزنا مثلاً لا يصلح لثبوت النسب والإرث ، وكذا الزواج بالمحارم لا يثبت النسب والإرث ، والسرقه لا تصلح سبباً لثبوت الملك ، والصلاة بغير طهارة باطلة ، وبيع الميتة باطل ، والباطل لا يترتب عليه حكم .

والحرام لغيره : هو ما يكون مشروعاً في الأصل ، واقترب به عارض اقتضى تحريمه ، كالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ، والبيع الذي فيه غش ، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، وصوم الوصال ، وزواج المحلل ، والطلاق البدعي ونحو ذلك مما حرم لعارض ، فليس التحريم لذات الفعل ، ولكن لأمر خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة .

وحكمه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه ، فهو عند الحنفية يصلح سبباً شرعياً ، وتترتب عليه آثاره ، فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطه للفرض ، والمصلي آثم ؛ لأنه ارتكب الغصب . والبيع المشتل على الربا أو على شرط فاسد ، بيع فاسد لا باطل ، فإذا قبض العوضان ، ثبت الملك فيهما للعاقدين ، لكنه ملك خبيث يجب إزالة سبب الفساد فيه ، لنهي الشارع عنه .

والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب ، وإنما في وصفه ، ما دامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به خلل في أصل السبب ووصفه ، بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده ، فيخرج عن كونه مشروعاً . والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالمعقود عليه ، أو بأهلية العاقد ، والوصف : ما يتعلق بأمر طارئ مكمل للعقد ، كجهالة المبيع أو الثمن ، أو الصفقتين في صفقة واحدة ، أو الزيادة في الأموال الربوية .

٤ - المكروه

تعريفه ، حكمه ، اصطلاح الحنفية فيه .

تعريف المكروه :

المكروه : هو ما طلب الشارع تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام^(١) . وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها ، مثل قوله ﷺ : « إن الله حرم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات^(٢) ، وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال^(٣) ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » ، وقوله ﷺ أيضاً : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ، أو بصيغة النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة ، مثل قوله سبحانه : ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١/٥] ، فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة ، وهو قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة : ١٠١/٥] ، وقوله ﷺ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لأن الأمر نفسه مشتبه فيه ، فلا يوصف بالحل والحرمه .

وحكم المكروه : أن فاعله لا يستحق العقاب ، وقد يستحق اللوم والعتاب .

اصطلاح الحنفية في المكروه :

قال الحنفية : إن المكروه نوعان^(٤) :

١ - المكروه تحريماً : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني ، كأخبار الآحاد ، مثل البيع على بيع الآخر ، والخطبة على خطبة الآخر ، كلاهما

(١) المستصفى : ٤٣/١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦٣ .

(٢) أي منع ما أمر الله ألا ينع ، وطلب ما لا يستحق طلبه .

(٣) أي نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره ؛ لأنه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب .

(٤) التقرير والتحجير : ٨٠/٢ .

مكروه للنهي عنهما في حديث نبوي أحادي النقل . ويختلف المكروه التحريمي عن الحرام في أن الحرام ثبت النهي عنه بدليل قطعي : قرآن أو سنة متواترة أو مشهورة ، كالسرقة والزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل ، ويكفر منكره . أما المكروه التحريمي فلا يكفر منكره ، وكهو في الحقيقة إلى الحرام أقرب ، كما قال الشيخان : أبو حنيفة وأبو يوسف .

٢ - المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع تركه ، لا على وجه الحتم والإلزام ، كأكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب ، والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير ، وترك السنن المؤكدة وغيرها .

وحكمه : أن فعله لا يستوجب العقاب ولا الذم ، ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل .

وعلى هذا تكون أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام ، وعند الجمهور خمسة أقسام . والراجح مذهب الجمهور .

٥ - المباح

تعريفه ، حكمه .

تعريف المباح :

المباح : لغة المعلن والمأذون ، وعند الأصوليين : هو ما خيّر الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه^(١) .

وتعريف الإباحة : إما بمادة الحل أو الإباحة ، مثل قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة : ٥] ، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ [النساء : ٢٤/٤] ، أو برفع الإثم أو الجناح أو الحرج ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُوا حَدُودَ اللَّهِ

(١) الإحكام للآمدي : ٦٣/١ .

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴿ [البقرة : ٢٢٩/٢] ، ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [البقرة : ٢٣٥/٢] ، ﴿ لَيْسَ عَلَى الْوَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ .. ﴾ [الفتح : ١٧/٤٨] .

وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى الإباحة ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢/٥] ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة : ١٠/٦٢] ، ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة : ١٨٧/٢] .

وتعرف الإباحة أحياناً باستصحاب الأصل كما تقدم ، إذ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ، لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ [البقرة : ٢٩/٢] .

وحكم المباح : أنه لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه .

الحكم الوضعي وأنواعه

الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة .

وأنواعه كما يتضح من التعريف سبعة :

١ - السبب :

السبب في اللغة : معناه الحبل وما يتوصل به إلى غيره ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [الحج : ١٥/٢٢] ، وعند الأصوليين : هو وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي ^(١) . وقد عرفنا في مبحث القياس أن السبب أعم من العلة ، فكل علة سبب ، وليس كل سبب علة .

(١) شرح العضد : ٧/٢ ، إرشاد الفحول : ص ٦ .

أنواعه :

قد يكون السبب مناسباً للحكم فيسمى علة ، مثل السفر سبب لجواز الفطر في رمضان ، وهو مناسب ظاهر ، لتضمنه المشقة التي تقتضي الترخيص . والإسكار سبب لتحريم الخمر ، وهو وصف مناسب ؛ لأنه يذهب العقولة ويضعفها . والقتل العمد العدوان سببه مناسب لوجوب القصاص ؛ لأنه يمنع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس والدماء . وهذا يسمى أيضاً علة .

وقد يكون غير مناسب ، كدلك الشمس ، هو سبب لوجوب صلاة الظهر ، في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء : ٧٨/١٧] ، وعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم . وشهود شهر رمضان سبب لوجوب الصيام ، في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥/٢] ، وقوله ﷺ : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » . والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم . وأشهر الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع ، في قوله تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة : ١٩٧/٢] ، ولا ندرك مناسبة معقولة بين السبب والحكم . ويسمى هذا سبباً لا علة .

وقد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي ، كما تقدم في الأمثلة السابقة ، المناسب وغير المناسب منها ، ومثل ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة ، والسرقة سبب لإيجاب قطع اليد ، والمرض سبب لإباحة الفطر في رمضان .

وقد يكون السبب سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتها ، كالبيع لإثبات الملك وإزالته ، والوقف والعق لإسقاط الملك ، والزواج لإثبات الحل ، والطلاق لإزالته ، والقربة لاستحقاق الإرث ، وإتلاف المال لاستحقاق الضمان على المتلف .

والسبب إما مقدور للمكلف ، كالقتل العمد سبب لإيجاب القصاص ، والعقود من بيع وإجارة وزواج أسباب لأحكامها المترتبة عليها ، وإما غير مقدور للمكلف ،

كدخول الوقت لإيجاب الصلاة ، والصغر لثبوت الولاية على الصغير ، والقراية للإرث .

وحكم السب : أنه إذا وجد ترتب عليه مسببه حتماً ، سواء أكان مسببه حكماً تكليفاً أم إثبات ملك أو حل أم إزالتها ؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعاً ، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده ، فمن سافر ثبت له إباحة الفطر في رمضان ، سواء أقصد أم لم يقصد ، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة الزوجة ، ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها ، ولو قال : لا رجعة لي ؛ لأن المسبب بترتيب الشارع لا من الإنسان ، وتم الربط بين المسبب والمسبب بصنع الله وإرادته .

٢ - الشرط :

الشرط في اللغة : مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه ، وجمعه شروط ، وبتحريك الراء معناه العلامة ، وجمعه أشراط ، كما قال تعالى : ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد : ١٨/٤٧] ، أي علامات الساعة . وعند الأصوليين : هو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه^(١) . والقييد الأخير لإخراج السبب ، فإنه يفضي إلى المسبب كما عرفنا ، لأنه يترتب على وجود السبب وجود المسبب ، وعلى عدم السبب عدم المسبب . مثل الطهارة للصلاة ، وحولان الحول لوجوب الزكاة ، والقدرة على تسليم المبيع لصحة البيع ، والزوجية لإيقاع الطلاق ، والإحصان لسببية الزنا للرجم ، والرشد لدفع مال اليتيم إليه ، فإذا لم توجد هذه الشروط لم يوجد الحكم ، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .

والشرط يكلل السبب ويحقق أثره المترتب عليه ، فعقد البيع سبب لانتقال الملكية

(١) المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦٨ ، إرشاد الفحول : ص ٦ .

إذا توافرت شروطه ، وعقد الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطه ومنها حضور الشاهدين ، والقتل سبب للقصاص بشرط كونه عمداً عدواناً ، أي بغير حق .

الفرق بين الركن والشرط : يتوقف وجود الشيء على كل من الركن والشرط ، إلا أن الركن عند الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من حقيقته ، فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها ، وكذلك القراءة في الصلاة ركن ، والإيجاب والقبول ركن العقد ؛ لأنه جزء من حقيقته . والشرط : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن حقيقته ، فالطهارة شرط في الصلاة ، وهي أمر خارج عن الحقيقة ، وحضور الشاهدين شرط في الزواج ، وتعيين العوضين في البيع شرط ، وكلاهما خارج عن العقد .

والخلل في الركن يؤدي إلى بطلان العقد ، أما الخلل في الشرط أي في وصف العقد الخارج عن حقيقته يؤدي عند الحنفية إلى فساد العقد .

أنواع الشرط :

قد يكون الشرط شرطاً للحكم ، كحولان الحول لوجوب الزكاة ، والقدرة على التسليم شرط لانعقاد البيع ، وقد يكون شرطاً للسبب كالإحصان شرط لسببيه الزنا لوجوب الرجم ، وكون القتل عمداً عدواناً لسببيه القتل لإيجاب القصاص^(١) .

والشرط إما شرعي وإما جعلي ، والشرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه بحكم الشرع كشروط العقود والعبادات وإقامة الحدود .

والشرط الجعلي : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته ، كشروط الواقف والواهب والموصي ، وشروط الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته ، وشرط أحد العاقدين في البيع على الآخر ، كأن يبيعه منزلاً على أن يسكنه شهراً أو أكثر .

(١) مرة الأصول : ٤٢١/٢ .

والشرط الجعلي المقبول : هو ما كان غير منافي حكم العقد ، فإذا تنافى مع حكم العقد ، بطل العقد ، وبناء عليه ، يبطل البيع أو الزواج المعلق على شرط أو المضاف إلى وقت في المستقبل ، مثل إن نجحت بعثك الكتاب ، وإن توظفت يافلانة تزوجتك ، فلا يصح العقد ؛ لأن حكمه لا يتراخى عنه ، ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد . وهذا هو الشرط المعلق والشرط المضاف للمستقبل . فإن لم يتناف الشرط مع مقتضى العقد ، صح وعدل آثار العقد ، كأن يبيع المنزل لآخر على أن يسكنه سنة ، أو يتزوج امرأة على أن يقيم معها في منزل أبيها . وهذا هو الشرط المقيّد المقترن بالعقد الذي يحقق منفعة لأحد العاقدين .

وهكذا إذا اعتبر الشرع الشرط الجعلي ، صار كالشرط الشرعي ، وإذا لم يعتبره الشرع بطل ولا يعتبر مثله .

٣ - المانع :

المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب^(١) . فيكون المانع نوعين : مانعاً للحكم ومانعاً للسبب^(٢) .

ومانع الحكم : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه ، مع تحقق السبب ، كالشبهة المانعة من إقامة الحد ، والأبوة المانعة من القصاص عند الجمهور غير المالكية ، واختلاف الدين المانع من الإرث .

ومانع السبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب ، كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة عند الجمهور غير الشافعية ؛ لكونه مانعاً من تحقق السبب وهو ملك النصاب ؛ لأن ما يقابل الدين ليس مملوكاً للمدين على الحقيقة ، نظراً لتعلق حقوق الدائنين به . وحرية المعقود عليه وهو الإنسان الحر مانعة من تحقق سبب الملك وهو البيع ، ويكون البيع باطلاً .

(١) إرشاد الفحول : ص ٦ .

(٢) شرح العضد : ٧/٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦٩ ، شرح جمع الجوامع : ٧٤/١ .

٤ ، ٥ - الصحيح والباطل :

الصحيح : هو ما استوفى أركان الشيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره الشرعية . فالصحيح من العبادات عند الفقهاء : أن يقع الفعل على وجه يسقط القضاء ، فمن صلى على ظن الطهارة ، كانت صلاته فاسدة لعدم سقوط القضاء . والصحيح من المعاملات : ما ترتب عليه أثره الشرعي ، أي ما شرع له ، كحل الانتفاع في البيع ، والاستمتاع في الزواج .

وغير الصحيح : هو ما صدر من أفعال المكلفين غير مستوف أركانه وشروطه على الكيفية المطلوبة ، ولم تترتب عليه آثاره الشرعية . وهذا يسمى عند الجمهور الباطل والفساد ، فهما بمعنى واحد عندهم ، سواء في العبادات والمعاملات ، فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة ، لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذمة ، والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يؤدي إلى نقل الملكية في البدلين ، ولا يترتب عليه حكم شرعي ^(١) .

وقال الحنفية : لا فرق بين الباطل والفساد في العبادات ، فهي إما صحيحة أو غير صحيحة ، ولا في الزواج ، فالزواج الباطل كالزواج الفاسد لا يفيد حل المتعة ولا يترتب عليه أثره ، وأما في العقود والتصرفات أي في المعاملات المدنية فالعقد إما صحيح أو باطل أو فاسد ^(٢) .

والباطل : هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد وأساسه ، بأن كان في الضيغة أو العاقدين أو المعقود عليه ، ولا يترتب عليه أثر شرعي ، كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي لا يعقل (غير مميز) أو يكون بيعاً لمعدوم ، أو زواجاً ياحدى المحارم .

(١) الإحكام للآمدي : ٦٧/١ - ٦٨ ، كشف الأسرار : ٢٥٨/١ ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ٨/٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٦٩ .

(٢) مرآة الأصول : ٢٨٩/٢ .

والفاسد : هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في ناحية فرعية متممة له ، أي في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، ويترتب عليه بعض الآثار إذا توافرت أركان التصرف وأموره الأساسية ، كالبيع بثن مجهول ، أو المقترن بشرط فاسد ، والزواج بغير شهود ، وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض الآثار ، فتنقل الملكية الحبيثة بالقبض في البيع الفاسد ، ويجب المهر والعدة في الزواج الفاسد ، ويثبت فيه النسب بالدخول .

٦ ، ٧ - العزيمة والرخصة :

العزيمة عند الأصوليين : هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء^(١) لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال ، كالصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام . وهي إما واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة . ويدخل تحت العزيمة : ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر ، كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص . ولا تطلق العزيمة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها .

والرخصة عند الأصوليين : هي ما شرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس ، أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة ، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي^(٢) . والعذر : كالاضطراب ومشقة السفر ، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها ، وإباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه . وأمثلة الرخصة : التلفظ بالكفر عند الإكراه ، والأكل من الميتة عند الضرورة ، فالعذر في الأول : هو الإكراه ، وفي الثاني : هو ضرورة حفظ النفس ، مع بقاء سبب الحكم الأصلي ، وهو في الأول : وجود أدلة وجوب الإيمان وحرمة الكفر ، وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبق

(١) معنى شرعيتها ابتداء : أنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها .

(٢) كشف الأسرار : ٦١٨/١ ، شرح العضد : ٨/٢ ، شرح الإنسوي : ٩١/١ ، روضة الناظر : ١٧١/١

وما بعدها .

السبب الموجب للحكم الأصلي ، إباحة ترك المسلم الثبات أمام عشرة من الكفار ، بعد أن كان ممنوعاً ، فلا يسمى رخصة ؛ لأن الحكم الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه ، وهو قلة المسلمين ، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات ، لم يكونوا قلة ، وإنما كانوا كثرة .

أنواع الرخصة :

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع^(٢) :

أ - إباحة الفعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة : كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على القتل أو قطع عضو ، مع اطمئنان القلب بالإيمان ، لقوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلُوبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل : ١٠٧/١٦] ، وكالإفطار في رمضان عند الإكراه ، وإتلاف مال غيره عند الإكراه ، وحل الأكل من الميتة عند الجوع الشديد ، وإباحة شرب الخمر عند الظم الشديد ، وإباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس من حاكم ظالم ، وحكمه الجواز إلا إذا خاف الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه ، فيصبح العمل بالرخصة حينئذ واجباً ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥/٢] . لكن الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه على الكفر ، كما أبان النبي ﷺ في إقرار صحابي مجاملة مسيلة الكذاب وموافقته على زعمه بأنه نبي ، قائلاً : « صدع بالحق فهنيئاً له » ، لكن يلاحظ أن هناك أموراً ثلاثة لا تحل بذاتها بحال ، وإن كان يرخص ببعض أحوالها ، وهي الكفر والقتل والزنا ، يرخص بالنطق بالكفر ، لكن الكفر في ذاته لا يحل أبداً وكذا الباقي .

ب - إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف : إباحة الفطر في

(٢) فواتح الرحموت : ب/١١٦ وما بعدها ، التقرير والتحرير : ١٤٦٢ .

رمضان للمسافر والمريض ، لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤/٢] .

٣ - إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع مخالفتها للقواعد المقررة ، كعقد السلم ، فإنه بيع لمعدوم ، وبيع المعدوم باطل ، ولكن الشرع أجاز له حاجة الناس إليه . ومثله عقد الاستصناع .

٤ - رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة ، والتخفيف فيها عن الأمة الإسلامية ، كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان ، وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة ، وإيجاب ربع المال في الزكاة ، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص .

والخلاصة : أن الرخصة عند الحنفية ، إما مباح أو واجب ، وقسموا الرخصة أيضاً إلى رخصة ترفيه ، ورخصة إسقاط .

ورخصة الترفيه : يكون حكم العزيمة معها باقياً ودليلاً قائماً ، ولكن رخص في تركه تخفيفاً عن المكلف ، كما بينا في النوع الأول كالتلطف بالكفر عند الإكراه ، وإتلاف مال غيره أو الفطر في رمضان عند الإكراه . ورخصة الإسقاط : لا يكون حكم العزيمة معها باقياً ، كإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد أو الظم الشديد ، فإن حرمة الأكل أو الشرب سقطت حال الاضطرار .

والظاهر أن لا معنى لهذه التفرقة ؛ لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال الإكراه وحال الاضطرار ؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار ، وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة . وإن كل الرخص شرعت للترفيه والتخفيف مع بقاء حكم الحظر ودليله ، كل ما في الأمر أنه لا إثم في فعل المحظور .

وكون الرخصة من أنواع الحكم الوضعي واضح ؛ لأن الضرورة سبب في إباحة الحظر ، وطروء العذر سبب في التخفيف بترك الواجب ، ودفع الحرج سبب في تصحيح بعض العقود .

المبحث الثاني - الحاكم

الحاكم في الشريعة : هو الله عز وجل باتفاق العلماء ، سواء عرف حكمه بالوحي ، أو بالاجتهاد ، ولهذا قالوا : الحكم : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، يَقْصُ الْحَقُّ ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام : ٥٧/٦] .

وإنما الخلاف بين العلماء فيما يعرف به حكم الله ، فهل لابد لذلك من الشرع ، أو إن العقل يمكنه إدراك الأحكام قبل بعثة النبي ؟ وهذا هو موضوع التحسين والتقبيح العقلي .

للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب^(١) :

الأول - مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ) : وهو أن الحسن والقبح شرعيان ، وليس للعقل أن يدرك حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الكتب والرسول ؛ لأن العقول تختلف اختلافاً بيناً في الأفعال ، فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبحها . ولذا يكون كل ما أمر به الشرع كالإيمان والصلاة والحج هو حسن ، وما نهى عنه كالكفر وغيره من المحرمات هو قبيح ، ولا يقال : ما رآه العقل حسناً فهو عند الله حسن ، ومطلوب فعله ، ويثاب عليه فاعله ، وما رآه العقل قبيحاً فهو عند الله قبيح ، ومطلوب تركه ، ويعاقب فاعله .

وبناء عليه ، لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة رسول وشرع من الله ، ولا ثواب ولا عقاب ، فمن عاش في عزلة تامة عن العالم ولم تبلغه دعوة

(١) التلويح على التوضيح : ١٧٢/١ ، شرح العضد : ٢٠٠/١ ، شرح الإنشائي : ٦٦/١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ١٣٦ ، إرشاد الفحول : ص ٦ .

رسول ولا شرع ، فهو ناج غير مكلف ، وأهل الفترة : وهم الذين عاشوا بين فترتي رسولين ناجون غير مكلفين بشيء ، ولا يستحقون ثواباً ولا عقاباً ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء : ١٥/١٧] .

الثاني - مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء (١٣١ هـ) وعمرو بن عبيد (١٤٤ هـ) : وهو أن الحسن والقبح عقليان ، فيمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسول وكتاب ، بناء على ما يوجد في الأفعال من صفات نفع أو ضرر ، وما رآه العقل حسناً فهو مطلوب لله ويثاب فاعله ، وما رآه العقل قبيحاً فهو واجب الترك ويعاقب فاعله .

وبناء عليه ، كل من لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله ، هم مكلفون بما ترشده إليه عقولهم ، فيفعلون ما تستحسنه عقولهم ، ويتركون ما تستقبحه عقولهم ؛ لأن كل عاقل يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة وشكر النعمة ، ويدرك قبح الكذب والغدر والخيانة وكفر النعمة .

الثالث - مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي (٣٣٣ هـ) ومنهم أئمة الحنفية : وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقفان على الشرع ، بل يدركها العقل ، بناء على ما في الأفعال من خواص وآثار ، فما رآه العقل السليم حسناً فهو حسن ، وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح ، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا في حسن أو قبح ؛ لأن العقول قد تخطئ .

وهذا هو المذهب الوسط والمعقول والمعتدل ، فأصول الأخلاق والفضائل يدرك العقل حسنهما لما فيها من نفع ، وأصول الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر .

وبناء عليه ، لا تعد ذمة العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطلب شيء فعلاً أو تركاً ، ولا جزاء من الله مطلقاً قبل ورود الشرائع ، وإن اتفقوا مع المعتزلة في أن العقول صالحة لإدراك منافع الثواب أو العقاب في بعض الأفعال .

وتنحصر ثمرة الخلاف بين هذه المذاهب فيمن لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع ، أما من بلغتهم الشرائع ، فقياس الحسن والقبح للأفعال : هو ماورد في الشريعة ، لا ما تدركه عقولهم بالاتفاق ، فما أمر به الشرع فهو حسن ، وما نهى عنه فهو قبيح .

المبحث الثالث - المحكوم فيه

تعريفه ، شروطه ، أقسامه .

تعريف المحكوم فيه :

المحكوم فيه أو به : هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخيراً أو وضعاً ، مثاله قوله تعالى : ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] ، فيه إيجاب تعلق بفعل وهو إقامة الصلاة ، فجعله واجباً ، وكذا ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة : ١/٥] ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢/٢] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ﴾ [الأنعام : ١٥١/٦] ، تضمن تحريماً تعلق بفعل هو قتل النفس ، فجعله حراماً . وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧/٢] ، اشتمل على الكراهة المتعلقة بفعل من أفعال المكلفين ، وهو إنفاق المال الخبيث ، فجعله مكروهاً . وقوله عز وجل : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة : ١٠/٦٢] ، فيه إباحة الانتشار في الأرض ، تعلق بفعل المكلف . ومثله : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤/٢] ، تعلق الخطاب بفعل وهو المرض والسفر ، فجعل كلاً منها مباحاً للفطر .

والمحكوم فيه في الحكم التكليفي : لا يكون إلا فعلاً مقدوراً للمكلف ، فجعله واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً ، لذا قالوا : لا تكليف إلا بفعل^(١) ، أي أن حكم الشرع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف . والمكلف به في التحريم والكراهة هو كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه .

(١) فواتح الرحموت : ١٣٢/١ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٥٩ .

وأما في الحكم الوضعي : فقد يكون فعلاً للمكلف ، وقد لا يكون فعلاً له ، ولكنه يؤول إلى فعله ، كدلوک الشمس سبب وجوب الصلاة على المكلف ، فإن تعلّق الحكم الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحكم التكليفي من جهة كونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً منه .

شروط المحكوم فيه :

يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط ^(١) :

أ - أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه ويستطيع القيام به كما طلب منه : فلا يكلف الإنسان بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها ؛ لأن الأمر القرآني بها محمل : ﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣/٢] ، ولا بد من بيان المحمل من الرسول ﷺ ، وقد فعل فقال : « صَلُّوا كما رأيتموني أصلي » . ومثل ذلك بقية الفرائض كالزكاة والصوم والحج نصوصها مجملة ، فلا يصح التكليف بها إلا بعد بيانها . وتلك هي مهمة النبي ﷺ كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤/١٦] .

وليس المراد بهذا العلم أن يعلم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأحكام ، وإنما المراد أن يكون في إمكانه العلم به والتعرف عليه ، وذلك بوجوده في دار الإسلام ، لذا قرر الفقهاء : لا يقبل في دار الإسلام الاعتذار بالجهل بالأحكام .

٢ - أن يعلم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة وامثالاً لأوامر الله : لأن الطاعة موافقة الأمر ، والامثال جعل الأمر مثالاً يحتذى . وهذا واضح في كل قانون لا بد من صدوره ونشره بين الناس في الجريدة الرسمية . والمراد هنا أيضاً إمكان العلم بالطلب ، لا العلم به بالفعل .

(١) للمستصفي : ٥٥/١ ، فواتح الرحموت : ١٢٣/١ ، شرح العضد : ١١/٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٥٨ .

٣ - أن يكون الفعل المكلف به ممكناً ، فيستطيع الإنسان أن يفعله وأن يتركه :
ويترتب على هذا الشرط أمور ثلاثة :

أحدها - أنه لا يصح التكليف بالمستحيل ، سواء أكان مستحيلاً لذاته أم مستحيلاً
لغيره ، والأول : هو ما لا يتصور العقل وجوده ، كالجمع بين الضدين أو النقيضين ،
والحصول في حيزين في وقت واحد ، مثاله : إيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد
في وقت واحد .

والمستحيل لغيره : هو ما يتصور العقل وجوده ، ولكن لم تجر العادة بحصوله ،
كالطيران للإنسان بدون طائفة ، وخلق الأجسام ، وحمل الجبل العظيم ؛ لأن
ما لا يتصور وجوده عقلاً أو عادة لا يمكن المكلف أن يفعله ، وليس هو في وسعه ،
والتكليف بحسب الوسع .

ثانيها - أنه لا يصح شرعاً تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلاً ، أو يكف غيره
عن فعل ؛ لأنه ليس ممكناً له ، وهو تكليف بما لا يطاق ، فلا يكلف إنسان بأن يصلي
أخوه أو يزكي أبوه أو يكف جاره عن السرقة ، وإنما يكلف فقط بالنصح والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثالثها - أنه لا يصح شرعاً التكليف بالأمور الجبليّة التي لا كسب للإنسان فيها
ولا اختيار ، كحمرة الخجل والخوف ، والفرح والبغض ، والحب واشتهاء الطعام
والشراب ونحو ذلك من الغرائز ؛ لأنها ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره ، وإنما
هي خارجة عن قدرته ، ومنها ميل القلب نحو بعض الزوجات أكثر من الأخرى .

وإذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الأمور ، فهو مصروف عن
ظاهره ، ويكون التكليف لما يسبق الشيء أو يعقبه ، مثل قوله تعالى :
﴿ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢] ، يراد به الحث على الإسلام ،
وقوله سبحانه : ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُختالٍ فَخَوِرَ ﴿ [الحديد : ٢٢/٥٧] ، يراد به منع الناس من السخط حال الحزن ، والتعالي والمفاخرة والبطر حال السرور . وقوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » لا يراد به حقيقة الحب ، وإنما المراد الطاعة والامتثال . وقوله ﷺ : « لا تغضب » لا ينصب النهي على الغضب ذاته ؛ لأنه أمر طبيعي غير مقدور للإنسان ، ويكون المقصود الابتعاد عن أسباب الغضب ، أو مجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام . وحديث « كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل » يراد به ألا تغضب غيرك ولا تعتدي عليه ، ولا يقصد به أن يقتله غيره .

التكليف بالشاق من الأفعال :

لا يلزم من اشتراط كون الفعل مقدوراً للمكلف ألا يتضمن التكليف أية مشقة على المكلف ؛ لأنه لا تعارض بين كون الفعل مقدوراً وكونه شاقاً ، فكل تكليف لا يخلو من مشقة ، لكن تفضل الله علينا برفع عنا الحرج ووضع عنا الإصر أو المشقة غير المحتملة أو الزائدة ، وعليه فإن المشقة نوعان : معتادة وغير معتادة^(١) .

١ - المشقة المعتادة : هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر به ، وهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا ، فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة ؛ لأن التكليف : هو طلب ما فيه كلفة ومشقة ، لكن هذه المشقة محتملة .

غير أن المشقة ذاتها ليست مقصودة للشارع الحكيم من تشريع الأعمال التي كلفنا بها ، بل المقصود المصالح المترتبة عليها ، فليس المقصود بالصيام إيلام النفس بالجوع والعطش ، بل المقصود صفاء الروح ، وصحة الجسد ، وتنمية عاطفة الرحمة .

وإذا لم تكن المشقة مقصودة ، فلا يصح قصد المشقات والزيادة منها ، فمن ترك

(١) تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السائس : ص ٢٥ .

طريقاً معبداً إلى المسجد ، وسلك طريقاً متعثراً صعباً ، ينبغي بفعله زيادة الأجر ، فقد أخطأ القصد ولا ثواب له .

٢ - **المشقة غير المعتادة :** وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عادة ، وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها ، وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة غالباً . وهذه لم يقع التكليف بها شرعاً ؛ لأن الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج والعنت الشديد ، كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل والحج ماشياً ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج : ٧٨/٢٢] ، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥/٢] ، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفاً ﴾ [النساء : ٢٨/٤] ، وقوله ﷺ : « بعثت بالحنيفية السمحة » ، « وما خير النبي ﷺ بين شيئين إلا اختار أسيرهما ما لم يكن مأثماً » ، ولثبوت مشروعية الرخص كالقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك ، ولدفع الضرر عن الناس وتكليفهم بما ليس في وسعهم .

وهذه المشقة إن كانت في العمل نفسه ، فقد رفعها الله في الرخص ورغب في الأخذ بها ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه » . وإذا لم تكن المشقة في العمل نفسه ، بل يجلبها المكلف على نفسه بإرادته ، فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه .

وما ورد في الأحاديث الدالة على احتساب الأجر على المشي إلى العبادة وأن الثواب على قدر المشقة ، ليس المقصود منها المشقة نفسها ، وإنما الترغيب في السعي وأمور أخرى كفضيلة المحل المنتقل إليه أو عنه أو للصبر على المشقة ليعظم الأجر ، وعليه تكون المشقة في الجهاد تابعة لامتبوعة ولا مقصودة .

أقسام المحكوم فيه :

قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حكم الله تعالى إلى أربعة أقسام : ما هو حق

خالص لله ، وما هو حق خالص للعبد ، وما اجتمع فيه حقان وحق الله غالب ، وما اجتمع فيه حقان وحق العبد غالب^(١) .

حق الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد ، فينسب إلى الله تعالى ، لعظم خطره وشمول نفعه ، أي أنه حق للمجتمع ، وشرع حكمه لمصلحة عامة ، لا لمصلحة فرد معين .

حق العبد : ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره . وأبين كل قسم بإيجاز .

القسم الأول - ما هو حق خالص لله تعالى :

وحكمه أنه ليس للإنسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود ، وينقسم إلى ثمانية أنواع :

١ - عبادات محضة : كالإيمان وأركان الإسلام الخمسة ، يقصد بها إقامة الدين ، وحكمة تشريعها : رعاية المصلحة العامة لا مصلحة المكلف وحده .

٢ - عبادة فيها معنى المؤونة : المؤونة : هي الضريبة التي تؤدي إلى المحافظة على ما تؤدي عنه من نفس أو مال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على المحتاجين ، فتشترط فيها النية ، وهي مؤونة لوجوبها على المكلف بسبب غيره كخادمه وابنه الصغير ، كوجوب نفقتها عليه ، فلا يشترط فيها كمال الأهلية كالعبادات المحضة ، فوجبت في مال الصبي والمجنون .

٣ - مؤونة فيها معنى العبادة : كعشور الأراضي الزراعية على الزرع والثر ، وهي مؤونة في مقابل بقاء الأرض في يد أهلها ، ولتكينهم من المحافظة عليها دون عدوان من أحد . وهي عبادة لتعلقها بالناء كزكاة المال ، فتصرف في مصارف الزكاة .

(١) التقرير والتعبير : ١٠٤/٢ ، كشف الأسرار : ١٣٦/٢ .

٤ - مؤونة فيها معنى العقوبة : كالحراج فإنه مؤونة في نظير بقاء الأرض في يد أهلها ، والمحافضة عليها من العدوان ، وكونه عقوبة لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد والاشتغال باستثمار الأرض . لكن يلاحظ أن واضع الحراج وهو سيدنا عمر لم يكن يقصد بها عقوبة القائمين على استثمار الأراضي .

٥ - عقوبة كاملة : كالحدود على الزنا والسرقه وشرب الخمر والتعزيرات ، فإنها عقوبات خالصة لله تعالى ؛ لأن تشريعها للمصلحة العامة ، فلا تسقط بالتنازل عنها من أحد .

٦ - عقوبة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول ، فإنه عقوبة ناقصة في معنى العقوبة ، لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له ، مع وجود سبب الاستحقاق وهو القرابة ، دون إلحاق ألم في بدن القاتل ولا نقصان في ماله . لذا لا يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه ، ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع المورث في بئر حفرها الوارث في غير ملكه ؛ لأن السبب ليس بقتل حقيقة .

٧ - عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات ، كالكفارات ، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل خطأ ، واشتغالها على معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة كالصوم والعتق والإطعام ، ويؤديها الشخص بنفسه كسائر العبادات .

٨ - حق قائم بنفسه : لم يتعلق بذمة أحد يؤديه على أنه طاعة ، وهو خمس المعادن والكنوز والغنائم ، واقتقاد معنى الطاعة فيه سبب لعدم اشتراط النية له ، ويصرف في المصالح العامة .

القسم الثاني - حقوق العباد :

وهي ما يكون المقصود منها صيانة مصلحة الفرد ، مثل بدل المتلفات وملك المبيع والتمن وحبس المرتين العين المرهونة ، وحق الشفعة . وحكمه : أنه يجوز لصاحبه التنازل

عنه أو استيفاءه ؛ لأن لكل مكلف أن يتصرف في حق نفسه ، وهذه الحقوق ليست من المصالح العامة .

القسم الثالث - ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب :

وهو حد القذف في رأي الحنفية ، فكونه يؤدي إلى صيانة أعراض الناس ، يجعله من حقوق الله تعالى ، وكونه يدفع العار عن المقدوف ويصون شرفه وكرامته ، يجعله من حقوق الأفراد أو العباد ، وتغلب الجهة الأولى ، فلا يسقط بعفو المقدوف .

وعند الشافعية : حق العبد هو الغالب في حد القذف . وبه يتبين أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق لله ، أي للمجتمع .

القسم الرابع - ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب :

كالقصاص من القاتل عمداً عدواناً ، فإنه حق لله تعالى لصيانة الدماء وحفظ الأمن ، وهو أيضاً حق للعبد ؛ لأنه يحقق مصلحة أولياء الدم ، فيطفئ نار الحقد والغيظ عندهم ، وتغلب الجهة الثانية ؛ لأنه يمس المجني عليه أكثر مما يمس المجتمع ونظامه ، فلا بد من طلب ولي الدم ، وله أن يتنازل عنه أو يأخذ بدلاً مالياً عنه ، ويستوفيه الحاكم أو القاضي ، ويمكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحاكم ولي الدم . وبهذا تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعلت في القصاص حقين : حقاً للمجتمع وحقاً للفرد ، أما القوانين فجعلت العقوبة حقاً خالصاً للمجتمع ، كما أن القوانين جعلت عقوبة الزوجة التي ثبت زناها حقاً شخصياً للزوج ، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى منه ، وله أن يوقف إجراءات الدعوى ، أما الشريعة فجعلت هذه العقوبة حقاً خالصاً لله ، أي للمجتمع .

المبحث الرابع - المحكوم عليه

تعريفه ، ما يشترط فيه ، الأهلية وعوارضها .

تعريف المحكوم عليه :

هو الإنسان الذي تعلق بفعله خطاب الشارع أو حكمه . ويسمى المكلف .

ويشترط فيه شرطان^(١) :

أ - أن يكون المحكوم عليه المكلف قادراً على فهم دليل التكليف : لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال . والقدرة على الفهم تكون بالعقل ؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك ، وبه يمكن الامتثال . ولما كان العقل من الأمور الخفية ، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس وهو البلوغ عاقلاً ، والبلوغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر على نحو كامل واضح ، فلا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم توافر العقل المطلوب لفهم دليل التكليف ، ولا يكلف الغافل والنائم والسكران ؛ لقوله ﷺ : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق » .

وأما إيجاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضمان المتلفات على الصبي والمجنون ، فليس تكليفاً لهما ، وإنما هو تكليف للولي بأداء حق المال من مالهما .

وأما نهى السكران عن الصلاة في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء : ٤٣/٤] ، فليس نهياً عن الصلاة حال السكر ، وإنما نهى عن السكر في وقت إرادة الصلاة حال الصحو .

(١) فواتح الرحموت : ١٤٣/١ ، شرح المضد : ١٤/٢ ، الإحكام للآمدي : ٧٨/١ ، المدخل إلى مذهب

أحمد : ص ٥٨ .

وأما نفاذ طلاق السكران عند الجمهور ، فليس من باب التكليف في شيء ، بل من باب خطاب الوضع ، يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفاذه ، كما جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة ، والمقصود به العقوبة والزجر .

أما مطالبة غير العرب بالتكاليف الشرعية ، باعتبار أن رسالة الإسلام شاملة عامة للناس جميعاً ، وهم لا يفهمون اللغة العربية ، فيتم بأحد أمرين : ترجمة التكاليف الشرعية إلى اللغات الأجنبية ، أو تخصيص فئة متعلمة تدرس الدين دراسة صحيحة ، ثم تتعلم اللغات الأجنبية ، وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله ، وهذا فرض كفاية ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤/٣] .

ويلاحظ أن ترجمة نصوص القرآن ذاتها أمر متعذر ، وإنما تترجم معاني القرآن ، على أنها ليست هي القرآن ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، وتحدى الله به الناس للإتيان بمثله أو بمثل سورة منه ، فهو معجزة الرسول الخالدة أبد الدهر التي تنطق بإعجاز القرآن في أسلوبه ونظمه ، وبلاغته وبيانه ، ومعانيه ، وقصصه ، وإخباره بالمغيبات .

٢ - أن يكون المكلف أهلاً للتكليف : والأهلية في اللغة : الصلاحية ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا ﴾ [الفتح : ٢٧٤٨] ، وتحقق بالعقل والفهم . وعند الأصوليين : هي صلاحية الإنسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات . وهي نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء^(١) .

وأهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق ، وتجب عليه واجبات ، وأساسها : وجود الحياة ، وتسمى عند الفقهاء : الذمة : وهي وصف شرعي

(١) مرآة الأصول : ٤٣٥/٢ ، حاشية نسمات الأسعار : ص ٢٧٢ .

يصير به الإنسان أهلاً لما يجب له وعليه . والأدق التمييز بين الأهلية وهي
الصلاحية ، وبين الذمة التي هي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان .
وتسمى الأهلية عند القانونيين : الشخصية القانونية .

وأهلية الوجوب : تثبت لكل إنسان منذ بدء تكونه جنيناً ، وتستمر معه إلى الموت
في جميع أطوار الحياة : لأنها مبنية على خاصية فطرية في الإنسان .

وأهلية الأداء : هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد
به شرعاً . وأساس ثبوتها التمييز بالعقل ، وهي مترادف المسؤولية ، فإذا صلى الإنسان
أو صام أو حج ، صحت عباداته ، وإذا صدر منه عقد أو تصرف ، صح شرعاً وترتبت
عليه أحكامه ، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض ، عوقب على جنايته .

أدوار الأهلية :

ير الإنسان منذ بدء تكونه جنيناً في بطن أمه إلى وقت بلوغه بأربعة أدوار
تكون فيها أهليته إما ناقصة أو كاملة . وهي دور الاجتنان ، ودور الصبا أو الطفولة ،
ودور التمييز ، ودور البلوغ عاقلاً ، علماً بأن دور الصبا يبدأ من الولادة وينتهي ببلوغه
سن السابعة . ودور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ .

وكل نوع من أنواع الأهلية في هذه الأدوار إما ناقصة أو كاملة .

أما أهلية الوجوب الناقصة : فتثبت للجنين في بطن أمه ، فتثبت له حقوق من
غير واجبات بشرط ولادته حياً ، كالإرث والوصية والاستحقاق في الوقف والنسب ،
ولا تصح منه الهبة والصدقة والشراء له ، ولو من وليه ، ولا تجب في ماله نفقة
أقاربه ، ولا يلزم بأثمان المشتريات . وتقصر أهليته لسببين : كونه جزءاً من أمه ،
وكونه نفساً مستقلة . ونظراً لأن وجوده محتمل يشترط لثبوت الحقوق له
انفصاله عن أمه حياً ، فلو انفصل ميتاً لم يثبت له شيء من الميراث أو الوصية
أو الوقف .

وأهلية الوجوب الكاملة : تثبت للإنسان منذ ولادته ، ولا تفارقه في أثناء حياته ، فيصلح لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات . ولا يوجد إنسان فاقده لهذه الأهلية . لكن الصبي قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كاملة ، فيكتسب الحقوق ، ويتحمل الواجبات التي يجوز للولي أداؤها عنه ، كالنفقات والزكاة وصدقة الفطر . وليس له أهلية أداء مطلقاً لضعفه وقصور عقله ، فتعد عقوده وعقود المجنون باطلة لا يترتب عليها أي أثر شرعي ، وإنما يؤاخذان مالياً لا بدنياً في الجناية على نفس إنسان آخر أو ماله ، ويباشر الولي من أب أو جد أو وصي عنها العقود والتصرفات التي يحتاجان إليها .

وأهلية الأداء الناقصة : تثبت للإنسان في دور التمييز إلى البلوغ ، وهي واضحة في الصبي المميز ومثله المعتوه ضعيف الإدراك والتمييز الذي لم يصل به العتة إلى درجة اختلال العقل وفقده .

أما عبادات المميز كالإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج ، فتصح منه ، ولكنه لا يلزم بها .

وأما تصرفاته فثلاثة أقسام :

١ - تصرفات نافعة نفعاً محضاً : وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل ، كقبول الهبة والصدقة دون إذن وليه ، ووجوب الأجرة له بإجارة نفسه ، وصحة وكالته عن غيره ؛ تصح منه وتنفذ ؛ لأن فيها تدريباً على التصرف ، لقوله تعالى : ﴿ وَابْتَئُوا الْيَتَامَى ﴾ [النساء : ٦٤] .

٢ - تصرفات ضارة ضرراً محضاً : وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون مقابل ، كالطلاق والعتق والهبة والصدقة والوقف والكفالة ، وهذه لا تصح منه ، ولو بإجازة الولي ؛ لأن الولي لا يملك هذه التصرفات .

٣ - تصرفات مترددة بين النفع والضرر : وهي التي تحتل الربح والخسارة كالبيع والشراء والإجارة والزواج ونحوها ، وهذه تصح من المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي ، فإذا لم يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية والمالكية على إجازته ، لنقص أهلية المميز ، فإذا أجاز نفذت وإلا بطلت .

وأهلية الأداء الكاملة : تثبت لمن بلغ الحلم عاقلاً . والبلوغ يحصل إما بالأمارات الطبيعية كالاختلام والحيض ، أو بتمام الخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء . وحينئذ يصبح الإنسان أهلاً لجميع التكاليف الشرعية ، ويجب عليه أداؤها ويأثم بتركها إن كانت عبادات ، وتصح منه جميع العقود والتصرفات ، وتترتب عليه آثارها ، ويؤاخذ على جميع الأعمال الصادرة منه ، سواء أكانت مدنية أم جنائية .

عوارض الأهلية :

قد تعترض بعض العوارض على أهلية الأداء ، فتؤثر فيها بإزالة أو النقصان أو بتغيير بعض أحكامها ، وهي نوعان :

عوارض سماوية : وهي التي لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب .

وعوارض مكتسبة : وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها . والسماوية أشد تأثيراً وأكثر تغييراً .

والعوارض السماوية أحد عشر عارضاً : وهي الجنون والصغر والعتة والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت .

والعوارض المكتسبة سبعة : وهي الجهل والسكر والمهزل والسفه والخطأ والإكراه . ويلحق بالسفه : الدّين أو المديونية .

وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء ، فليس للمجنون والنائم والمغمى عليه أهلية أداء أصلاً ، ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الشرعية ،

والواجبات المالية على المجنون يؤديها عنه وليه ، والواجبات البدنية أو المالية على النائم والمغمى عليه يؤديها كل منهما بعد يقظته .

وقد ينقص العارض أهلية الأداء ولا يزيلها كالعته الخفيف : وهو الذي يكون معه إدراك وتمييز ، فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصبي المميز . وأما العته الشديد : وهو الذي لا يكون معه إدراك وتمييز ، يكون صاحبه كالمجنون في بطلان تصرفاته .

وقد يقتصر أثر العارض على تغيير بعض الأحكام لمصالح معينة ، كالسفه والمديونية (الدّين) والغفلة ، فيحجر على السفه والمغفل (ذي الغفلة) في التصرفات المالية من معاوضات وتبرعات ، فلا تصح منها ، محافظة على مالهما .

ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق الدائنين كالتبرعات ، محافظة على حقوق دائنيه .

ولا يجوز عند الإمام أبي حنيفة الحجر بسبب السفه والغفلة والمديونية ، حفاظاً على الكرامة الإنسانية ؛ لأن هذه العوارض لا تؤثر في أهلية الإنسان ، والضرر الذي يلحق الإنسان أكبر من المصلحة التي تترتب على الحجر .

وكذلك الإكراه سواء أكان ملجئاً تاماً أم غير ملجئ ناقصاً لا يؤثر في الأهلية بنوعيتها ، لبقاء الاختيار معه ، لكن للإكراه أثر في الأقوال والأفعال الصادرة من المستكره . والإكراه الملجئ : هو التهديد بالقتل أو القطع ، وحكمه : أنه يفسد الاختيار ويعدم الرضا ، والإكراه غير الملجئ أو الناقص : هو التهديد بالحبس لمدة قصيرة والضرب غير المتلف ، وحكمه : أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . فإن كان المكره عليه من الإقرارات ، بطل الإقرار ، سواء أكان ملجئاً أم غير ملجئ ، فمن أكره على الاعتراف بمال أو زواج أو طلاق ، كان اعترافه باطلاً .

وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات كالبيع والإجارة والرهن ، كان أثر الإكراه فيها الفساد عند الحنفية ، لا البطلان ، سواء أكان الإكراه ملجئاً أم غير ملجئ . لكنهم استثنوا بعض التصرفات فقالوا بصحتها مع الإكراه وهي الزواج والطلاق عند الحنفية والعقود والرجعة والنذر واليمين .

وإن كان المكره عليه من الأفعال كالقتل وشرب الخمر والإتلاف ، ففي الإكراه الناقص يكون المستكره هو المسؤول . وأما في حال الإكراه الملجئ فالأفعال ثلاثة أنواع :

نوع يجب فعله ويأثم عنه الممتنع كالإكراه على شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو الخنزير ؛ لأن المستكره يكون في حال الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات .

ونوع يرخص فعله ، لكن الصبر عليه أفضل كالكفر بالله تعالى ، فإنه لو صبر كان إعزازاً للدين ، ويلحق به إفساد صوم رمضان ، وترك الصلاة المفروضة ، وإتلاف مال الآخرين .

ونوع لا يحل فعله بحال وهو القتل وقطع العضو والضرب المؤدي إلى الهلاك ، ولو فعله كان آثماً ؛ لأنه أثر نفسه على غيره . أما القصاص فيجب عند الجمهور على الفاعل المباشر ، لمباشرته القتل ظلماً وعدواناً ، وعند أبي حنيفة ومحمد : القصاص على المكره ، لكن يعزر الفاعل بما يراه الإمام زاجراً له عن هذا الفعل . ويلحق الزنا بهذا النوع ؛ لأن الزنا لا يرخص فيه بحال ، لكن لا حد على أحد ، لأن الإكراه شبهة يدرأ بها الحد .